

제19장

기일과 기간

제1절	총 설	172
제2절	기일의 지정	173
제3절	기일의 통지	186
제4절	기일의 변경	197
제5절	기일의 실시	203
제6절	기일의 해태	211
제7절	기일지정신청	228
제8절	소송절차의 기간	235

제1절 총 설

1. 기 일

민사소송절차의 신속과 경제의 이상을 실현하기 위한 시간적 제약 요소로서 기일과 기간의 제도가 있다. 민사소송법은 법원이 많은 사건을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여, 소송절차상 기일과 기간에 관하여는 직권주의를 도입하여 그 주도권을 법원에 맡기고 있다.

일반적으로 기일이란 법원이 당사자 기타 소송관계인(증인·감정인·보조참가인 등)과 일정한 장소에 모여 소송행위를 함께 하기 위하여 미리 지정한 일시를 말한다. 기일은 연월일 및 개시시각을 표시하여 지정되지만 지정된 시각 그 자체가 기일이 아니고 개시된 때부터 그 종료에 이르기까지의 시간 전체가 기일이다.

기일은 그때 행하여질 소송행위의 목적에 따라서 변론준비기일, 변론기일, 증거조사기일(증인신문기일·검증기일·서증조사기일 등), 판결선고기일 등으로 불린다. 그중에서 가장 중요한 변론준비기일 또는 변론기일은 바로 변론의 준비 또는 변론을 목적으로 지정하여 실시되는 기일이다. 다만 변론준비기일과 변론기일에서는 통상 당사자가 자신의 주장사실을 증명하기 위한 증거조사가 병행되고 있어서, 사실상 변론준비기일과 변론기일에는 증거조사기일이 포함, 실시되고 있는 것이 실무관행이다.

변론이 수회의 기일에 걸쳐 열린 경우라도 법적 효과는 1회의 변론기일에 계속 변론이 행해진 경우와 같게 된다. 다시 말하면 뒤의 기일의 변론은 항상 선행기일까지의 변론을 전제로 하여 계속 실시된다. 따라서 법관이 바뀐 경우를 제외하고는 각 기일마다 변론을 갱신할 필요가 없는데 이를 변론의 일체성이라 부른다.

한편 이와 같이 수회에 걸쳐 열린 각 기일에서의 변론 내용은 각 기일마

다 독립된 별도의 조서에 기재되어야 하는데(민소 152조), 이를 1기일 1조서의 원칙이라 부른다.

2. 기 간

소송행위는 단독행위인지 쌍방행위인지를 불문하고 그 준비 또는 효력발생을 위하여 일정한 시간의 경과를 필요로 하게 되는데, 이를 기간이라고 한다. 또한 소송절차의 신속한 진행을 꾀하기 위하여 소송행위를 할 수 있는 시기에 관하여도 일정한 제한이 필요하다.

그러므로 민사소송법은 소송행위에 대하여 여러 가지 기간을 두어, 그 신축을 법원의 직권에 맡기면서(민소 172조 1항 본문), 신축할 수 없는 기간에 관하여는 추후보완(172조 1항 단서, 173조)을 허용하고 있다.

제19장

기
일
과
기
간

제2절 기일의 지정

1. 총 설

민사소송절차에서 기일의 진행은 원칙적으로 법원이 주재하며, 기일이 정하여지면 소송관계인이 그 정해진 기일과 장소에 모여 소송행위를 하게 된다.

2002년 개정 민사소송법에서는 변론기일 전 답변서 제출의무와 변론 없이 하는 판결 제도(민소 256조, 257조)를 도입하고 또한 원칙적으로 사건을 변론준비절차에 부치도록 하였다. 그러나 사건의 내용이나 심리의 어려움에 따른 사건의 분류 없이 대부분의 사건을 변론준비절차에 부쳐 반복적인 서면공방을 진행한 결과 심리 지연으로 당사자의 권리 구제가 늦어지는 경우가 많게 되자, 2008년 개정 민사소송법에서는 변론 없이 판결하는 경우(257조) 외에는 원칙적으로 바로 변론기일을 정하되 필요한 경우에는 사건을 변론준비절차에 부치도록 함으로써(258조 1항) 민사소송절차에서 신속과 소송

경제라는 이상과 적정이라는 이상이 조화를 이루도록 하였다.

2. 지정권자

기일은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 소송절차를 주재하는 재판장이 지정한다(민소 165조 1항 본문). 단독사건인 경우에는 해당 단독판사가 지정한다.

다만 수명법관이나 수탁판사가 주재하여 신문하거나 또는 심문하는 기일은 그 수명법관이나 수탁판사가 지정한다(민소 165조 1항 단서). 수명법관이나 수탁판사가 지정한 기일에 대하여는 그 수명법관 등에게 기일을 변경할 권한도 있다. 변론준비기일은 변론준비절차를 진행하는 재판장등(재판장, 수명법관, 수탁판사)이 지정한다(282조 1항). 변론준비기일에서 합의부 재판장은 자신을 수명법관으로 지정할 필요 없이 재판장 지위에서 기일을 진행한다. 이 점에서 합의부 재판장이 수소법원 조정기일을 혼자 담당하기 위해서는 자신을 수명법관으로 지정해야 하는 것(민소 7조 5항)과 차이가 있다. 변론준비절차를 종결하는 경우에는 재판장등이 변론기일을 미리 지정할 수 있으므로(민소 284조 2항), 이때에는 재판장뿐만 수명법관이나 수탁판사도 직접 변론기일을 지정할 수 있다. 수명법관, 수탁판사가 변론준비절차를 종결하면서 변론기일이 추후지정 상태로 방치되지 않도록 하기 위한 조항으로서, 수명법관등은 변론준비기일 전에 재판장과 미리 협의하여 변론기일로 지정가능한 일시를 확인함이 바람직하다.

한편 소액사건에서는 양쪽 당사자가 임의로 법원에 출석하여 변론하는 방식으로 소송을 개시할 수 있으므로(소액 5조), 개별 사건에 관한 재판장의 기일지정 절차 없이 바로 기일이 개시되는 것도 가능하기는 하다. 다만 재판장이 재정하지 않는 상태에서 변론이 열릴 수는 없으므로, 재판장이 소액사건 법정에 참석 가능한 일시는 미리 지정되어 있을 필요가 있다.

3. 지정절차

가. 직권주의 원칙

기일의 지정은 소송의 진행과 직접 관련되는데, 소송의 진행에 관하여는 직권주의가 적용되므로, 모든 기일은 앞서 본 지정권자가 직권으로 지정하고 당사자의 기일지정신청은 그 직권발동을 촉구하는 데 불과함이 원칙이다. 다만 당사자의 기일지정신청이 법적 효과를 갖는 예외적인 경우가 있다. 예를 들어 양쪽 당사자가 2회 불출석한 경우 발생하는 소취하 간주의 효과를 저지하기 위해서 당사자가 기일지정신청을 할 수 있다(민소 268조 2항, 민소규 67조). 이러한 기일지정신청이 있으면 통상 바로 다음 변론기일을 지정하여 통지하게 될 것이지만(민소 268조 3항), 따로 기일지정 기한이 규정되어 있지는 않으므로 바로 변론기일을 지정할 수 없는 특별한 사정이 있다면 일단 기일지정을 보류한 다음 그러한 사정이 해소된 다음 변론기일을 지정하는 것도 가능할 것이다. 이때에는 그와 같이 추후 지정된 변론기일이 민사소송법 268조 3항의 '기일지정신청에 따라 정한 변론기일'에 해당할 것이다.

나. 당사자의 기일지정신청 및 처리

당사자는 신청에 의하여 기일의 지정을 촉구할 수 있다(민소 165조 1항). 당사자의 이러한 신청은 보통 기일지정신청이라 불리며, 이는 지정권자의 직권발동을 촉구하는 의미가 있는 데 불과하다고 설명되고 있으나, 법조문에 당사자의 신청이 가능하다고 명시되어 있는 점을 고려하여 당분간 기일지정을 하지 않기로 판단하는 경우 당사자로 하여금 그러한 판단을 인식할 수 있도록 조치함이 바람직할 것이다. 예컨대 전자소송에서 기일지정 신청문에 대하여 불허를 뜻하는 '부' 결재를 하면, 별도의 고지·통지 조치를 취하지 않아도 곧바로 당사자는 전자기록뷰어에서 그 '부' 표시를 볼 수 있다.

기일지정신청의 유형에 관하여 보면, 지정권자가 소송절차의 진행에 장애가 없음에도 불구하고 필요한 기일의 지정을 하지 않고 있는 때 당사자

가 기일의 지정(즉 소송절차의 진행)을 촉구하는 경우도 있고, 일단 지정되어 있는 기일을 다른 기일로 변경하여 줄 것을 희망하는 경우(기일변경신청)도 있다.

당사자의 기일지정신청은 서면 또는 말로 할 수 있다(민소 161조). 서면으로 기일지정신청을 하는 경우 신청서에 인지를 붙이지 아니하며(인지 10조 단서), 재판사무시스템에 문건으로 입력하고 기록에 가철한다(인지액·편철방법예규). 마찬가지로 당사자가 법정에서 말로 변론의 연기 또는 속행을 구하는 경우에도 이는 그 변론기일에서의 재판장의 소송지휘사항에 관한 단순한 희망의 표시에 불과하여 인지를 제출받아 조서에 붙일 필요가 없다.

기일지정신청은 전술과 같이 직권발동을 촉구하는 의미가 있는 데 불과하므로 그 신청이 있는 경우에 기일지정의 필요가 있다고 인정되면 적절한 기일지정을 하면 되나, 그렇지 않다고 인정되면 신청 기각의 재판 등으로써 응답할 필요 없이 종전의 소송상태를 그대로 두면 된다. 다만 특히 기일변경신청에 대한 응답이 없는 상황에서 당사자로서는 재판부가 기일변경을 불허한 것인지 아니면 아직까지 허부에 대한 검토를 하지 않은 것인지에 관하여 혼선이 생길 수 있다. 이에 따라 실무에서는 당사자의 기일준비상 편의를 위해 ‘부’의 경우 간이한 방법으로 통지하기도 한다.

변론준비절차가 예정한 서면공방이 종료되었거나 원고나 피고가 기한 내에 준비서면을 제출하지 않았거나(민소 284조 1항 2호) 준비서면에서 더 이상 주장할 사항이 없음을 명시한 경우 또는 별도의 기일지정신청서를 제출하거나 준비서면에 그 취지가 기재된 경우에는, 참여사무관은 곧바로 재판장에게 기록을 인계하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 해야 한다[사건관리예규 10. 나. (3), (4)].

그러나 소송종료 후 종료의 효력(소 취하 또는 취하간주)을 다투기 위하여 기일지정신청을 한 경우(민소 268조 3항, 민소규 67조)는 직권발동을 촉구하는 의미가 아니라, 소송이 아직 존속 중이라는 전제하에서 본안판결을 구하

는 신청에 해당하므로 반드시 변론을 열어 판결로써 응답하여야 하는데, 이 경우 재판사무시스템에 문건으로 입력한 후 기록에 가철한다. 자세한 내용은 제7절 참조.

4. 지정의 방법

가. 기일개시 시각과 시차제 기일지정

기일은 미리 연월일 및 개시시각과 장소를 밝혀서 지정하여야 한다. 영상 재판의 방식으로 기일을 여는 경우에는 그러한 취지 및 출석장소(비디오 등 중계장치에 의한 중계시설의 경우, 영상재판예규 30조 1항) 또는 인터넷주소(화상장치의 경우, 영상재판예규 16조 1항)도 기일통지서에 포함되어야 한다.

기일의 연월일을 정할 때에 필요한 경우(예컨대 증거조사기일의 경우에 증인 또는 감정인의 출석이 어렵거나 당사자 기타 소송관계인이 참여하기 어려운 때)에는 공휴일로도 지정할 수 있으나(민소 166조), 그렇지 않은 한 일요일 기타 휴일은 피하여야 한다. 시각을 정할 때에도 위와 같이 필요한 경우가 아닌 한, 정규 근무시간 외의 시간이나 야간으로 지정하는 것은 피하여야 한다. 그러나 소액사건의 경우에는 판사가 필요한 경우 근무시간 외의 시간이나 공휴일에도 개정할 수 있다(소액 7조의2).

하루에 여러 사건의 변론을 한 법정에서 행하는 경우에 재판장은 사건의 변론 개정시간을 구분하여 지정하여야 한다(민소규 39조).

변론은 집중되어야 하고 이를 위하여 당사자는 변론을 서면으로 준비하여야 하며(민소 272조 1항), 특히 법원은 변론준비절차를 마친 경우에는 첫 변론기일을 거친 뒤 바로 변론을 종결할 수 있도록 하여야 하므로(287조 1항), 효율적인 심리와 당사자의 편의를 위하여는 개정 시간을 사건 단위로 구분하여 시차제로 지정하는 것이 중요하다. 현재 재판실무에서는 10분 내지 20분 단위로 기일개시 시각(예: 10시, 10시 15분 등)을 세분하여 지정하고 있다. 다만 증인신문이나 시청각자료를 활용한 발표 등이 예정되어 있는 경우 예

상 소요시간을 감안하여 기일 간격을 정하는 등 당사자의 요청이나 사건의 내용에 따라 탄력적으로 기일을 지정할 필요가 있다.

기일을 지정함에 있어서 당사자나 대리인의 의견 개진이 있는 경우에는 가급적 그 의견을 존중하여 주는 것이 좋다. 통상 법정에서 차회 변론기일을 정하는 경우에는 미리 양쪽 당사자나 대리인의 의견을 물어서 기일을 지정하기 쉬우나, 첫 변론기일이나 변론준비기일은 당사자나 대리인이 언제 기일이 지정될지 모르고 있다가 갑자기 기일이 지정됨으로써 재판준비에 차질을 빚거나 다른 일정과 중복되어 곤란을 겪을 수 있다. 이러한 점을 감안하여 첫 변론기일 또는 변론준비기일을 바꾸는 것은 현저한 사유가 없는 경우라도 당사자들이 합의하면 이를 허가하도록 규정하고 있다(민소 165조 2항). 따라서 기일통지서에 지정기일에 출석할 수 없는 사정이 있는 경우 즉시 재판부에 알려주도록 하는 안내 문구를 포함시키는 방안 등을 적극 활용하여, 기일이 공전되지 않도록 하여야 할 것이다. 또한 통상 첫 기일이 당사자의 의견수렴 없이 지정되는 점을 고려하면, 당사자들의 전부 또는 일부가 실제로 출석하기 어려운 사정이 확인되는 경우 변경기일에 관한 합의가 이루어지지 않았더라도 기일 공전을 방지하기 위한 기일변경을 고려할 수 있을 것이다.

변론기일은 가능한 한 시간대를 세분하여 시차를 두고 기일을 지정하되, 충분한 변론시간이 확보되어야 하고(사건관리에규 11. 가.), 법원 소재지에서 먼 거리에 거주하는 당사자나 증인 등을 위해서는 그들이 출석 또는 귀가하기에 편리한 시간대를 지정하는 배려를 함이 바람직하다. 증인신문 등에 많은 시간이 소요될 것으로 판단되는 사건은 별도의 특별기일을 지정할 수도 있다.

나. 기일의 장소와 공개 여부

기일을 실시할 장소는 법정(이러한 시설을 갖춘 법원청사 내의 장소)으로 정하는 것이 원칙이다(법조 56조 1항). 매주 일정한 요일에 정기적으로 일정한 법정에서 변론기일을 여는 재판부의 경우에는 기일지정 시마다 일일이 그

법정을 표시할 필요가 없으나, 그 법정이 아닌 곳, 즉 판사실이라든가 법원 청사 밖의 장소에서 기일을 실시하고자 할 때에는 그 장소를 명시하여야 한다. 법원청사 밖의 장소에서 증거조사기일만을 실시할 때에는 재판부의 의사만으로 이를 할 수 있으나(민소 297조 1항), 법원청사 밖의 장소에서 변론 기일을 실시하고자 할 때에는 따로 법원장의 허가를 받아야 한다(법조 56조 2항). 후자의 경우에는 적절한 양식으로 일시·장소·사유 등을 명시하여 '법원 밖 개정 허가요청서'를 법원장에게 제출하여 법원장으로부터 허부에 관한 날인을 받고 그 서면을 기록에 철하여야 한다.

[법원 밖 개정 허가요청서]

○ ○ 법 원

제 ○ 민 사 부

사건번호 : 20 가합○○○○ 손해배상(기)

원 고 : ○○○외 ○○명

피 고 : ○○○

법원조직법 제56조 제2항의 규정에 의하여 위 사건에 관하여 다음과 같이 법원의 의 장소에서 개정하고자 하니 허가하여 주시기 바랍니다.

다 음

개정예정일시 : 20 . . . 14:00

(사건의 진행에 따라 계속 속행기일 지정 예정)

개정장소 : ○○지방법원 ○○시군법원

법정의 개정사유 : 당사자 본인들의 출석 및 변론을 위하여

20 . . .

재판장 판사 ○ ○ ○ ㉠

위 허가함

20 . . .

○ ○ 법원장 ㉠

제19장

기
일
과
기
간

영상재판 방식의 기일도 법원장의 허가가 있는 경우 법원 청사 외의 장소에서 열 수 있다(민소규 73조의4 1항). 영상재판 방식으로 참석하는 당사자들이 법원 외부에 있는 것은 민사소송법의 기본 전제이므로, 여기서 개정의 장소는 법원이 실제 위치한 곳을 기준으로 판단한다.

실무상 변론기일은 대부분 법정에서 진행되는 반면 변론준비기일은 법정보다는 준비절차실이나 심문실 또는 조정실을 주로 활용하고 있다. 이와 같이 변론준비기일을 법정 밖의 장소에서 진행할 경우에는 법복을 입지 아니한 상태로 편안한 분위기에서 진행할 수 있고(법관, 사법보좌관 및 법원사무관 등의 법복에 관한 규칙 2조 1항 참조) 실무상 합의부원이나 참여사무관등 없이 재판장만 참석함으로써 업무의 효율성을 높일 수도 있는 장점이 있다. 다만 당사자나 대리인이 대기할 수 있는 적절한 공간을 제공하고 기일진행순서에 관한 안내문을 게시하는 등 소송관계인에 대한 세심한 배려가 필요하다.

변론기일의 변론은 공개하여야 하는 것이 명백하나, 특히 법정 밖의 심문실이나 조정실에서 진행되는 변론준비기일을 공개하여야 하는지에 대해서는 논란이 있을 수 있다. 법원조직법 57조 1항에 의하여 공개할 심리는 변론절차에 국한되며 변론준비절차는 포함되지 않는다(대법원 2006. 10. 27. 선고 2004다69581 판결). 다만 당사자는 재판장등의 허가를 받아 변론준비기일에 제3자와 함께 출석할 수 있으므로(민소 282조 3항), 비록 변론준비기일을 비공개로 진행하더라도 실질적 당사자의 지위에 있거나 분쟁에 직접적이고 중요한 이해관계를 가지고 있거나 또는 당사자의 의사결정에 상당한 영향력을 가지고 있는 제3자를 당사자가 대동한 경우에는, 그 제3자를 기일에 참여시켜 효율적으로 쟁점을 정리하고 화해·조정에 의한 분쟁해결의 가능성을 넓히도록 함이 바람직하다.

실무상 심문실이나 조정실에서 변론준비기일을 여는 경우 당사자나 이해관계인 이외의 제3자가 방청을 시도하는 경우는 거의 없다. 이에 따라 공개여부가 아무런 문제가 되지 않은 상태에서 변론준비기일이 진행되기도 하는

데, 명시적으로 비공개 결정을 하거나 제3자의 방청을 제한하지 않은 이상 공개 상태로 진행하였다고 보더라도 무방할 것이다.

다. 기일지정에 따른 사무처리

재판장 등 기일지정권자의 기일지정행위는 명령에 해당한다. 다만 기일을 변경하는 경우와 같이 특히 필요한 경우가 아닌 한 재판서(명령)를 따로 작성하지 않고, 후술과 같이 재판사무시스템에 지정기일을 입력함으로써 행하는 것이 보통이다.

제19장

기
일
과
기
간

라. 최초의 변론(준비)기일의 지정

2002년 개정 민사소송법에서는, 재판장은 변론 없이 판결하는 경우와 변론준비절차를 따로 거칠 필요가 없는 경우 이외에는 모든 사건을 바로 변론준비절차에 부쳐야 하며, 서면에 의한 변론준비절차를 진행하는 동안에 주장 및 증거를 정리하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에 비로소 변론준비기일을 열도록 규정하였다. 즉 다툼이 있는 사건은 모두 변론준비절차에 회부하여 쟁점정리를 하는 것을 원칙으로 하면서, 필요한 경우 변론준비기일을 열도록 하였다.

그런데 민사소송절차가 변론기일을 중심으로 진행되도록 함으로써 당사자의 신속한 재판을 받을 권리를 보장하고 사건의 신속한 해결을 도모하기 위해서 2008년 민사소송법 개정을 통하여 재판장은 변론 없이 판결하는 경우(민소 219조, 257조 1항, 2항) 외에는 원칙적으로 바로 변론기일을 정하도록 규정하였다(258조 1항 본문). 이는 사건관리방식을 종전의 서면공방을 비롯한 변론준비절차 선행 방식에서 조기 변론기일 지정 방식으로 변경한 것으로, 재판부가 신속하게 변론기일에 당사자를 대면하여 쟁점을 정리하도록 하려는 취지이다. 위와 같은 민사소송법 개정취지에 따라, 재판장은 답변서가 제출되면 바로 사건을 검토하여 가능한 최단기간 안의 날로 제1회 변론

기일을 지정하여야 하고(민소규 69조 1항), 필요에 따라 사건을 변론준비절차에 부친 경우에도 변론준비절차가 끝난 경우에는 바로 변론기일을 정하여야 하며(민소 258조 2항), 첫 변론기일을 거친 뒤 바로 변론을 종결할 수 있도록 하여야 한다(287조 1항).

다만 효율적인 변론을 위해 당사자의 주장과 증거를 정리할 필요가 있는 경우에는 사건을 변론준비절차에 회부하는데(민소 258조 1항 단서), 특히 복잡한 사건의 경우 분쟁의 초기에 쟁점을 정리하고 다툼의 대상이 되는 실질적 쟁점의 범위를 확정하는 작업을 위하여 변론준비기일의 필요성이 인정된다. 이 경우 신속하게 변론준비기일을 지정함으로써 서면공방 반복에 따른 소송지연을 최소화할 수 있다.

개정 민사소송법은 변론준비절차는 변론이 효율적이고 집중적으로 실시될 수 있도록 당사자의 주장과 증거를 정리하는 절차임을 명확히 함으로써(민소 279조 1항), 주장서면을 기초로 한 당사자의 본격적인 공방 등 실질적인 변론이 이루어지는 변론기일과 변론을 위한 준비행위가 이루어지는 변론준비기일을 구분하였다.

따라서 재판장은 소장부분을 송달하고(민소 255조) 답변서를 제출하게 한 다음(256조), 답변서가 제출되면 사건을 검토하여 원칙적으로 가능한 최대한 기간 안의 날로 변론기일을 지정하되, 피고의 응소 여부 및 사안의 내용과 복잡성 등에 따라 다음과 같이 사건을 유형별로 심사, 분류하여 기일 진행 방식을 결정하여야 할 것이다.

첫째로, 피고가 소장부분을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하지 아니한 때 또는 청구의 원인된 사실을 모두 자백하는 취지의 답변서를 제출하고 따로 항변을 하지 아니한 때에는 변론 없이 판결할 수 있으므로, 바로 선고기일을 지정하여 통지하여야 한다(민소 257조). 만약 재판장이 소장부분 송달 시 미리 무변론판결의 선고기일까지 함께 지정하였다면 다시 선고기일을 통지할 필요 없이 해당 선고기일에 무변론판결을 선고하면 된

다. 반면 소장부분 송달 시 선고기일을 미리 지정하지 아니한 사건들에 대하여는 바로 선고기일을 지정하거나, 그 사건이 무변론판결을 하기에 부적합한 경우에는 최초의 변론기일을 지정하여야 할 것이다.

재판장은 답변서가 제출되지 않거나 자백 취지의 답변서가 제출되었음에도 무변론판결을 하지 아니하는 사건에 대하여 제1회 변론기일을 지정하여 당사자에게 통지할 때에 제1회 변론기일과 선고기일을 일괄 지정하여 당사자에게 [전산양식 A1603]과 같은 기일통지서를 송달할 수 있고, 피고가 그 기일통지서를 송달받은 후 제1회 변론기일까지 원고의 주장사실을 다투는 답변서를 제출하지 아니하거나 또는 모두 자백하는 취지의 답변서를 제출한 경우 법원은 별도의 선고기일통지서를 송달하지 않고 지정된 선고기일에 판결을 선고할 수 있다(제1회 변론기일 및 선고기일 일괄 지정에 관한 예규).

둘째로, 피고가 답변서를 제출하여 다투는 경우에는 바로 사건을 검토하여 원칙적으로 가능한 최단기간 안의 날로 제1회 변론기일을 지정하여 사건의 신속한 해결을 도모하여야 한다.

셋째로, 재판장이 답변서를 검토한 결과 쟁점과 증거의 정리를 위하여 필요하다고 판단하여 변론준비절차에 부친 경우에 재판장 등은 변론준비절차에서 쟁점과 증거의 정리, 그 밖에 효율적이고 신속한 변론진행을 위한 준비가 완료되도록 노력하여야 하며, 당사자는 이에 협력하여야 한다(민소규 70조 1항). 나아가 변론준비절차를 거친 사건의 경우 법원은 첫 변론기일을 거친 뒤 바로 변론을 종결할 수 있도록 하여야 하고(민소 287조 1항), 그 심리에 2일 이상이 소요되는 때에는 가능한 한 종결에 이르기까지 매일 변론을 진행하여야 하고 특별한 사정이 있는 경우에도 가능한 최단기간 안의 날로 다음 변론기일을 지정하여야 한다(민소규 72조 1항). 변론준비절차를 거친 사건의 경우 변론기일을 지정하는 때에는 당사자의 의견을 들어야 하며(2항), 이렇게 지정된 변론기일은 사실과 증거에 관한 조사가 충분하지 아니하다는 이유로 변경할 수 없다(3항).

마. 재판사무시스템을 통한 기일 지정

재판장이 재판사무시스템을 통해 최초의 변론기일 또는 변론준비기일을 입력하면, 법원사무관등이 기일통지 절차를 진행하게 된다. 법원사무관등이 기일입력 사실을 알지 못하면 기일통지가 적시에 이루어지지 않을 우려가 있으므로, 사전 업무협약(사건관리에규 4. 가.) 등을 통해 재판부의 정형적인 업무처리 방식을 정함이 바람직하다.

한편 재판장이 직접 기일을 입력하는 대신 법원사무관등에게 개별 기일 또는 기일지정 방식을 알려주는 경우에는, 법원사무관등이 재판사무시스템에 해당 기일을 입력한 후 기일통지 절차를 진행하게 된다.

바. 제2차 이후의 각종 기일의 지정

기일을 변경하거나 변론을 연기 또는 속행하여 제2차 이후의 변론(준비)기일을 지정하는 때에는 소송절차의 중단 또는 중지, 그 밖에 다른 특별한 사정이 없으면 다음 기일을 바로 지정하여야 하며, 다만 민사소송법 279조 2항에 따라 재판장이 변론기일을 연 뒤에 특별한 사정이 있어 사건을 변론준비절차에 부치는 경우에는 그러하지 아니하다(민소규 42조). 송달불능된 사건의 경우처럼 주소보정에 어려움이 있거나 사실조회절차나 회신의 지연으로 상당 시간이 소요될 가능성이 있는 경우에는, 예상 소요시간을 고려하여 다음 기일을 지정함으로써 무익한 기일진행이 되지 않도록 하여야 한다.

제2차 이후의 변론준비기일·변론기일과 증거조사기일·판결선고기일 등 소송진행 중에 열리는 모든 기일은 그 직전 변론(준비)기일에서 지정되는 것이 보통이다. 이때는 그 변론(준비)기일조서의 ‘고지된 다음 기일’란에 그 연월일시를 기입하는데 변론(준비)기일에서 증거조사기일이나 판결선고기일을 지정하는 등 다음 기일의 종류가 달라지는 경우에는 그 기일의 종류(검증·감정기일, 선고기일 등)도 함께 표시하여야 한다. 다음 변론기일과 함께 감정기일도 정하는 등 여러 종류의 기일을 한꺼번에 지정하는 경우에도 기일별로

종류를 표시하여야 한다.

기일 외에서 기일지정을 하는 경우에는 첫 기일 지정과 마찬가지로 재판장이 직접 재판사무시스템을 통해 기일을 입력하거나 또는 법원사무관등에게 지정된 기일을 알려주어 그로 하여금 재판사무시스템에 기일을 입력하게 하는 방법 중 하나를 택할 수 있다.

기일의 지정, 변경 및 속행은 오직 재판장등의 권한에 속하는 것이므로, 법원이 당사자의 증거조사를 위한 속행신청에도 불구하고 변론을 종결하였더라도 종국판결에 대한 불복절차에 의하여 그 판단의 당부를 다룰 수 있는 것은 별론으로 하고 별도로 항고로써 불복할 수는 없다(대법원 1989. 9. 7. 자 89마694 결정).

제19장

기
일
과
기
간

사. 기일의 추후지정 및 그 밖에 기일지정 시 주의할 사항

기일의 추후지정은 가능한 한 피하여야 한다(민소규 42조 참조). 다만 법률상 소송절차를 진행할 수 없거나(소송절차의 중단·중지 등) 관련사건의 결론이나 감정 결과 등을 기다려야 하기 때문에 기일을 지정함이 사실상 무의미하게 되는 등 특별한 사정이 있는 경우에는, 기일을 추후로 지정하고 대기할 수 있다. 이러한 경우에는 나중에 사무분담의 변경이나 인사이동 등으로 재판부의 변동이 있어 새로운 재판부가 그 사건을 처리할 때 추후지정의 사유를 알지 못하여 심리에 지장을 초래할 수도 있으므로, 조서에 그 추후지정하게 된 사유를 구체적으로 기재하여야 한다(조서예규 4조).

[기재례]

- ① 속행(감정서가 3개월 후에야 작성 완료될 예정이라는 양쪽 대리인의 진술에 의하여)
- ② 연기(관련사건인 소유권이전등기말소 청구사건이 2000. O. O. 대법원 2000다21345호로 접수되어 계속 중이라는 양쪽 대리인의 진술에 따라)

기일이 추후지정된 경우에도 법원으로서의 절차진행이 가능한 상태가 되었는지를 수시로 확인할 필요가 있다. 특히 추후지정 사건의 관리를 위해서는 재판사무시스템에서 제공하는 추후지정 사건조회(첫 기일, 추후지정된 기일, 추후지정 사유 등의 정보를 제공함)나 도과목록조회(미리 증거조사 등에 필요한 기간이 설정되어 있어야 함)를 통하여 점검하는 방법을 활용하면 편리하다. 특정 일자나 관련사건 종국 시점에 알림이 표시되도록 하는 기능을 활용할 수도 있다. 위와 같은 확인이 제대로 이루어지지 않는 경우 추후지정 사유가 해소되었음에도 후속절차가 진행되지 않아 사건이 지연될 우려가 있다. 이러한 점을 고려하여 기일을 바로 지정할 수 없는 사유가 있는 경우에도 추후지정 대신 일단 수개월 이후로 기일을 지정하고 해당 기일까지 추후지정 사유가 해소되지 않는 경우 다시 수개월 이후로 기일을 변경하는 방식도 실무상 활용되고 있다.

그 밖에 변론재개결정을 한 때에는 재판장은 특별한 사정이 없으면 그 결정과 동시에 다음 변론기일을 지정하여야 한다(민소규 43조).

제3절 기일의 통지

1. 총 설

‘기일의 통지’란 기일이 지정된 경우에 당사자 또는 기일에 출석하여야 할 소송관계인에게 그 기일이 지정된 사실을 알리는 것을 말한다. 2002년 개정 전 민사소송법에서는 모든 소송관계인에 대한 기일의 통지는 ‘소환장’의 송달에 의하여 소환하도록 규정하였으나, 현행 민사소송법은 기일에 참석할 권리가 있을 뿐 출석할 의무가 없는 당사자 등에게는 ‘기일통지서’를, 기일에 출석할 의무가 있는 증인 등에게는 ‘출석요구서’를 송달함으로써 기일을 통지하도록 바꾸었고, 또한 대법원규칙으로 새롭게 발전된 다양한 통신수단을

이용한 간이한 기일통지 방식을 활용할 수 있도록 개선하였다(민소 167조, 민소규 45조).

2. 기일통지의 방식

가. 통상의 방식: 기일통지서 또는 출석요구서의 송달

기일의 통지는 기일통지서 또는 출석요구서를 작성하여 송달하는 방식에 의하는 것이 원칙이다(민소 167조 1항 본문).

(1) 기일통지서 또는 출석요구서의 작성

출석의무가 없는 당사자에 대하여 소송행위의 기회를 주기 위한 통상의 기일통지는 ‘기일통지서’를 송달함으로써 충분하다. 심문(審問)(민소 82조 2항, 134조 2항, 347조 3항) 절차는 심문서 발송으로도 진행할 수 있으나, 따로 심문기일을 지정하는 경우에는 통상적으로 기일통지서를 송달한다. 반면 당사자라도 소송관계를 명료하게 하기 위한 석명처분(민소 140조 1항 1호), 화해의 권고(145조 2항), 당사자신문(367조)을 위하여 특히 당사자나 법정대리인의 출석을 명하여야 하는 경우와 제3자를 증인이나 감정인 등으로 채택하여 신문(민소 309조, 333조)하기 위하여 출석을 요구하는 경우에는 ‘출석요구서’를 송달하여야 한다. 한편 변론준비기일을 열어 당사자를 출석하게 하는 경우에는 출석명령[전산양식 A1637]을 작성하여 송달하여야 한다(282조 1항).

각종 기일통지서 또는 출석요구서는 송달사무의 처리자인 법원사무관등이 작성한다(민소 175조). 기일통지서와 출석요구서의 기재사항으로는 공통적으로 사건번호와 사건명, 출석하여야 할 기일의 일시와 장소 등을 기재하여야 하며, 특히 당사자나 증인·감정인의 출석을 요구하는 출석요구서에는 신문사항의 요지 등 법이 정한 사항(309조, 333조, 373조)과 출석을 요구하는 이유를 기재하여야 한다.

기일통지서와 출석요구서의 양식은 법원사무관리규칙 67조와 ‘재판사무

에 관한 문서의 양식에 관한 예규’에서 이를 정하고 있는데, 전산시스템에서 제공하는 각종 기일통지서(변론준비기일통지서[전산양식 A1600], 변론기일통지서[전산양식A1601], 그 밖에 [전산양식 A1602 내지 A1612-1])와 출석요구서(증인 출석요구서[전산양식 A1630], 감정인출석요구서[전산양식 A1632], 당사자 본인출석요구서[전산양식 A1636] 등)의 소정 양식에 해당사항을 입력한 다음 법원사무관등이 기명날인하여 작성한다.

위 양식들 중 기본이 되는 최초의 변론기일통지서[전산양식 A1601]와 증인출석요구서[전산양식 A1630]의 양식은 아래와 같으며, 양식 여백이나 이면에 법원위치도, 법정배치도, 대중교통안내 사항 등을 인쇄하여 사용할 수 있다.

[전산양식 A1601] 변론기일통지서(1심)

○ ○ 법 원 변론기일통지서 사 건 20 가 원 고 피 고 위 사건의 변론기일이 다음과 같이 지정되었으니 출석하시기 바랍니다. 일시 : 20 . . . : (소요예상시간 00분) 장소 : 제 호 법정 20 . . . 법원주사 ○ ○ ○ ㉠ ◇ 유 의 사 항 ◇ 1. 출석할 때에는 신분증을 가져오시고, 이 사건에 관하여 제출할 서면이 있는 경우에는 사건 번호(20 가)를 기재하여 미리(가능한 한 기일 7일 전) 제출하시기 바랍니다.

2. 합의부에서 심리하는 사건은 변호사(지배인 등 법률상 소송대리인 포함)가 아니면 소송대리가 허용되지 않습니다.
 3. 소송대리인이 선임되어 있더라도 되도록 당사자 본인(당사자가 회사 등 법인 또는 단체인 경우에는 대표자 또는 실무책임자, 당사자가 여러 명인 경우에는 의사결정을 할 수 있는 주된 당사자)도 함께 출석하시기 바랍니다.
 4. 전자소송포털 앱(아래 QR코드)이나 대한민국 법원 홈페이지(www.scourt.go.kr) ‘나의 사건 검색’을 이용하시면 재판기일 등 각종 정보를 편리하게 열람할 수 있습니다.
 5. 사건진행에 관하여 전화안내를 받고자 하는 경우에는 ‘(02) 3480-1100’을 이용하실 수 있습니다.
- ※ 주차시설이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

※ 문의사항 연락처 : ○○지방법원 제○단독 법원주사 ○○○
 전화(○○) ○○○ — ○○○○
 팩스(○○) ○○○ — ○○○○ e-mail :

제19장

기
일
과
기
간

[전산양식 A1630] 증인출석요구서

○ ○ 법 원

증인출석요구서

사 건 20○○가단○○ 손해배상(기)
 원 고 ○○○
 피 고 ○○○
 신문사항요지 별지와 같음(이미 증인진술서나 증언을 같음하는 서면을 제출한 때에는 그와 관련된 내용)

위 사건의 사실관계 등을 파악하기 위하여 귀하를 민사소송법 제303조(증인의 의무)에 따라 증인으로 채택하여 신문하게 되었으므로, 아래의 일시·장소에 출석하여 주시기 바랍니다.

일시 : 20 . . . : (소요예상시간 00분)

장소 : ○○지방법원 ○○호 법정

20○○. ○○. ○○.
 법원주사 ○○○ ㉠

◇ 유 의 사 항 ◇

1. 법원은 특별한 규정이 없으면 누구든지 증인으로 신문할 수 있습니다(민사소송법 제 303조).
 2. 부득이 위 기일에 출석할 수 없는 경우에는 그 사유를 밝혀 신속히 신고하시기 바랍니다. 멀리 떨어진 곳에 거주하여 출석이 현저히 불편하다고 인정되는 경우에는 거주지 근처 법원에 출석하여 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 증인신문을 진행하는 것도 가능하오니(민사소송법 제327조의 2), 불출석 사유와 함께 이러한 방식의 증인신문을 희망하는지 여부도 밝히시기 바랍니다.
 2. 정당한 사유 없이 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 500만 원 이하의 과태료를 부과하고 강제구인 할 수 있으며, 과태료를 부과 받고도 정당한 사유 없이 다시 출석하지 아니한 때에는 7일 이내의 감치에 처할 수 있습니다. 또한, 법원은 위와 같은 불출석으로 인한 소송비용의 부담을 명할 수 있습니다(민사소송법 제311조, 제312조).
 3. 출석할 때에는 본인 확인 및 증인여비지급을 위하여 신분증, 도장 및 계좌번호를 준비하고, 이 사건에 관하여 법원에 제출할 서면이 있는 경우에는 사건번호(20○○가 단○○)를 기재하시기 바랍니다.
 5. 대한민국법원 앱(아래 QR코드)이나 대한민국법원 홈페이지(www.scourt.go.kr) '나의 사건검색'을 이용하시면 재판기일 등 각종 정보를 편리하게 열람할 수 있습니다.
 6. 사건진행에 관하여 전화안내를 받고자 하는 경우에는 '(02) 3480-1100[또는 '각급 법원 대표번호']'를 이용하실 수 있습니다.
- ※ 주차시설이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

※ 그 밖의 문의사항 연락처 : ○○지방법원 제○단독 법원주사 ○○○
전화 : 팩스 : e-mail :

나의 사건검색 QR코드



(2) 기일통지서 또는 출석요구서의 송달

법원사무관등은 위와 같이 작성한 기일통지서와 출석요구서를 그 대상자에게 송달하여야 한다. 소송대리인이 있는 경우에는 당사자에 대한 기일통지서는 소송대리인에게 송달하여야 한다(민전 11조 2항). 기일의 통지를 받은 소송대리인이 그 뒤에 사임하더라도 당사자에 대한 송달의 효력에는 아무런 영향이 없으므로 본인에게 다시 기일을 통지할 필요는 없다(대법원 1963. 8. 22. 선고 63다271 판결). 다만 당사자신문 등을 위하여 당사자 본인의 출석을 요구할 때에는 소송대리인에 대한 기일통지만으로는 안 되고, 별도로 본인

에게 출석요구서를 송달하는 것이 원칙이다.

보조참가인의 소송수행권능은 피참가인으로부터 유래된 것이 아니라 독립의 권능이므로 피참가인과는 별도로 보조참가인에 대하여도 기일의 통지, 소송서류의 송달 등을 행하여야 하고, 보조참가인에게 기일통지서 또는 출석요구서를 송달하지 아니함으로써 변론의 기회를 부여하지 아니한 채 행하여진 기일의 진행은 적법한 것으로 볼 수 없다. 다만 기일통지서를 송달받지 못한 보조참가인이 변론기일에 직접 출석하여 변론할 기회를 가졌고, 위 변론 당시 기일통지서를 송달받지 못한 점에 관하여 이의를 하지 아니하였다면, 기일통지를 하지 않은 절차진행상의 흠이 치유된다(대법원 2007. 2. 22. 선고 2006다75641 판결).

송달에 필요한 비용(송달료)의 예납에 관하여는 제6장(접수사무) 참조.

전자적 송달 또는 통지는 법원사무관등이 송달할 전자문서를 전산정보처리시스템에 등재하고 그 사실을 송달받을 자에게 전자적으로 통지하는 방법으로 하는데(민전 11조 3항), 송달받을 자가 등재된 전자문서를 확인한 때 또는 확인하지 않는 경우 등재사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 본다(4항). 송달받을 자의 전자문서 확인 시점은 자동으로 전산정보처리시스템에 기록된다.

종이송달(민전규 29조 4항에 따라 전자우편을 이용하는 이른바 ‘e-post’ 송달 포함)의 경우 송달기관은 원칙적으로 송달에 관한 사유를 서면으로 법원에 통지하여야 한다(민소규 53조 본문). 따라서 종전에는 송달결과가 기재된 영수증·우편송달통지서나 집행관(법원경위) 송달보고서·공시송달보고서 등의 송달관련 서류를 작성순서와 도착순서에 따라 기록에 편철하였다. 그러나 법원이 상당하다고 인정하는 때에는 전자통신매체를 이용한 통지로 서면통지를 갈음할 수 있도록 변경되었고(53조 단서), 이에 따라 민사소송법 176조 2항에서 정한 우편에 의한 송달의 경우 송달에 관한 사유의 통지는 원칙적으로 전자송달통지서에 의하되 법원이 필요하다고 인정할 때에 한하여 우편

집배원으로 하여금 종이송달통지서에 의하여 송달에 관한 사유를 통지하게 할 수 있도록 변경되어(송달통지서 전산화에 따른 업무지침 3조) 현재 우편송달 통지서를 법원 전산시스템에 등록하고 원칙적으로 기록에 편철하지 않고 있다. 등기우편에 의한 발송송달을 하는 경우(민소 187조)에도 우체국이 전자 통신매체를 이용하여 법원에 특수우편물 접수사실 및 그 일시를 통지한 때에는 그 전자적 정보에 의하여 송달일시를 증명할 수 있으므로, 법원사무관 등이 위 전자적 정보를 확인하고 이를 전산시스템에 등록한 때에는 발송송달보고서[전산양식 A1406]를 작성하지 아니할 수 있다(송달예규 7조 3항, 4항).

피고가 원격지의 구치소 등에 수감되어 있어서 기일통지서 또는 출석요구서를 송달하였으나 구치소 측에서 차량과 계호인원의 부족 등의 이유로 출정시킬 수 없다고 통보한 경우, 그대로 재판을 진행함으로써 당사자의 소송 절차에 참여할 권리가 실제로 박탈되는 결과가 초래된다면 위법 내지는 부당한 재판진행이 될 여지가 있다. 소송대리인이 선임된 경우는 그대로 재판을 진행해도 무방하나, 소송대리인이 없다면 구치소 측과 상의하여 비디오 등 중계장치 등에 의한 중계시설을 통하여 기일을 진행하는 방안을 검토할 수 있다. 필요하다면 재판장등 또는 법원은 비디오 등 중계장치에 의한 중계 시설이 설치된 관공서나 그 밖의 공사단체의 장에게 영상기일의 원활한 진행에 필요한 조치를 요구할 수 있다(민소규 73조의3 3항). 영상재판이 적합하지 않거나 당사자가 직접 출석하는 방식을 희망한다면 구치소 측에서 통상 민사소송의 경우에도 그 관내 법원에는 당사자의 의사에 따라 출정시키는 현실을 고려하여, 피고의 보통재판적 소재지인 구치소의 관할법원으로 재량 이송함이 타당할 것이다. 다만 그 소송이 현재 계속 중인 법원이나 다른 법원의 전속관할에 속한다면 구치소의 관할법원으로의 이송은 불가능하다. 출소에정일이 얼마 남지 않았다면 원고의 의견을 들어 그 날 이후로 기일을 지정하여 재판을 진행하는 것이 바람직할 것이다.

한편 외국에서 할 송달은 시간이 오래 걸리는 것이 보통이므로 충분한 시

간적 여유를 두고 그 기일을 지정하되, 다음 기일 및 그다음 기일을 아울러 지정하여 기일을 통지하도록 하고 있다(외국에서 할 송달에 있어서의 변론기일 등 지정방법 재판예규). 외국송달에 관한 자세한 내용은 제40장(국제민사사법 공조) 참조.

나. 기일에 출석한 사람에 대한 고지

당해 사건으로 출석한 사람에 대하여는 기일을 직접 고지하면 기일을 통지한 것으로 되며(민소 167조 1항 단서), 따로 기일통지서 또는 출석요구서를 송달할 필요가 없다. 여기서 ‘그 사건으로 출석한 사람’이란 그 사건으로 변론기일에 법정에 출석한 사람에 한하지 않고, 그 사건의 검증기일 등 증거조사기일에 출석한 경우도 포함된다(대법원 1975. 3. 25. 선고 75다12 판결). 이와 같이 기일에 출석한 사람에 대한 기일고지는 조서의 기재에 의하여 명백하게 표시된다.

기일에 출석하여 재정 중인 경우 외에, 학설상으로는 그 사건의 기록열람·서류제출·비용예납 등을 위하여 법원 민원실 등에 출석한 경우도 포함된다. 그러나 그러한 경우에는 법원사무관등이 기일을 고지하여도 그 고지사실을 기록에 표시할 방법이 없기 때문에, 그 당사자의 양해를 얻어 마치 기일통지서 또는 출석요구서를 법원사무관등으로부터 교부송달받은 것처럼 영수증[전산양식 A1404]을 작성·제출받는 것이 실무이다. 원칙적으로는 그 당사자로부터 다음 기일에 출석하겠다는 출석승낙서를 받아두는 것이 좋다(민소 168조).

고지 대상자인 ‘출석한 사람’은 기일통지서 또는 출석요구서를 송달받을 자격이 있는 사람, 즉 당사자·법정대리인·소송대리인 또는 송달영수인에 한하므로(제20장(송달) 참조), 사무원·피용자·동거인 등에게 기일을 고지하는 것은 위법이다.

한편 변론기일 등의 기일에 출석한 당사자에 대하여 다음 기일을 고지하

였다 하더라도, 그 기일에 출석하지 아니한 다른 당사자에 대하여는 기일통지의 효력이 생기지 않음은 물론이다. 다만 판결선고기일에 관하여 판례는, 판결의 선고는 당사자가 재정하지 아니하는 경우에도 할 수 있는 것이므로 법원이 적법하게 변론을 진행한 후 이를 종결하고 판결선고기일을 고지한 때에는 재정하지 아니한 당사자에게도 그 효력이 있고, 그 당사자에 대하여 판결선고기일 소환장을 송달하지 아니하였다 하여도 이를 위법이라고 할 수 없다고 하고(대법원 2003. 4. 25. 선고 2002다72514 판결), 또 판결선고기일에 양쪽 당사자가 불출석하여 그 선고기일을 연기하여 고지한 경우에도 기일변경 및 다음 기일의 고지가 적법하다고 한다(대법원 1964. 7. 14. 선고 63다1069 판결). 그러나 현재의 실무에서는 불출석한 당사자에게도 변론이 종결되어 판결선고기일이 지정되었음을 안내하고 변론재개 신청의 기회를 준다는 의미에서 기일통지서를 송달하고 있다.

다. 출석승낙서의 제출

당사자·소송대리인·보조참가인·증인 또는 감정인 등과 같은 소송관계인이 재판장이 정한 기일에 출석하겠다고 적은 서면을 제출한 때에는 기일통지서 또는 출석요구서를 송달한 것과 같은 효력을 가진다(민소 168조). 소송관계인이 이미 기일을 알고 출석할 의사를 표시하고 있는 이상 별도로 기일통지서 또는 출석요구서를 송달할 필요가 없기 때문이다. 이러한 출석승낙서는 법원의 행위를 요구하는 서면이 아니므로 인지를 붙일 필요는 없다. 출석승낙서 양식은 [전산양식 A1409]와 같다.

주로 증인·감정인·당사자신문을 위하여 출석한 자가 신문을 주도할 소송대리인이나 대질신문을 하여야 할 대질증인이 출석하지 않았거나 법원의 사정으로 신문을 받지 아니하여 다음 기일에 다시 출석하여야 할 경우 또는 송달불능인 당사자가 사건의 진행상황을 알아보려고 법원에 나온 경우에 출석승낙서를 제출하게 하는 것이 원칙이지만, 실무에서는 그 대신 앞에서 본

기일고지의 경우처럼 그 증인이나 당사자로부터 다음 기일의 통지를 받았다는 취지의 영수증을 제출받는 방식으로 운영되고 있다.

라. 간이한 방법에 의한 기일통지

법원은 대법원규칙이 정하는 간이한 방법에 따라 기일을 통지할 수 있다(민소 167조 2항). 다만 이러한 간이한 방법에 의한 기일통지는 정상적인 기일통지와 달리 소송관계인이 현실적으로 기일을 통지받을 가능성이 낮다고 할 수 있으므로, 그 기일에 출석하지 못하더라도 이에 대한 법률상의 제재나 그 밖에 기일을 게을리함에 따른 불이익을 줄 수 없다(2항 단서). 그러나 간이방식 통지를 수령한 사람이 기일의 통지를 받았다는 출석승낙서나 영수증을 제출하였다면 불출석에 대한 제재나 불이익을 받게 될 수도 있다.

위 규정에 따른 기일의 간이방식 통지는 전화·팩시밀리·보통우편 또는 전자우편으로 하거나, 그 밖에 상당하다고 인정되는 방법으로 할 수 있는데(민소규 45조 1항), 향후 정보통신기술의 발전에 따라 그 방법은 더욱 다양해질 것이다. 이렇게 간이한 방법으로 기일을 통지한 때에는 법원사무관등은 그 방법과 날짜를 소송기록에 표시하여야 하는데(2항), 전자기록 사건에서는 공용부전지 기능을 이용하여 해당 내용을 입력한다(민전예규 57조 1항). 그 밖에 간이송달보고서[전산양식 A1407]를 작성하여 기록에 편철할 수 있고, 종이서면을 송달한 경우에는 기록에 편철할 대상서류(증거신청서나 감정서)나 그 사본(기일통지서 등)의 적당한 여백이나 또는 기록의 적당한 곳(무변론판결 대상 사건에서 원고에 대한 송달은 기록표지 다음면의 '기일 외에서 지정하는 기일'란의 '비고'란)에 통지의 방법·상대방과 그 일시를 적어둘 수도 있다(송달예규 4조).

마. 기일통지 방식을 위반한 경우의 효력

기일의 통지가 적법하지 않으면 기일을 실시할 수 없고, 실시하더라도 그 기일에서의 소송행위는 위법한 것이 된다(대법원 1962. 9. 20. 선고 62다380

판결). 따라서 소액사건이 아닌 일반 민사사건에서 판결로 소를 각하하기 위하여는, 법원이 변론을 연 경우에는 물론 변론 없이 하는 경우에도 반드시(변론을 연 경우에는 변론을 종결하고) 선고기일을 지정하여 당사자에게 기일을 통지하고 그 지정된 선고기일에 소각하의 종국판결을 선고하여야 할 것이므로, 위와 같은 절차를 거침이 없이 변론기일에 선고된 판결은 위법하다(대법원 1996. 5. 28. 선고 96누2699 판결). 이처럼 적법한 기일통지를 받지 못하여 기일에 출석할 수 없었기 때문에 패소판결을 받은 사람은, 기일에 정당하게 대리되지 않은 사람에 준하여 상소 또는 재심절차에 의하여 구제될 수 있을 것이다. 제1심법원이 부적법한 발송송달에 기초하여 변론기일을 통지하고 변론을 종결한 후 판결선고기일을 지정·고지한 것은 제1심판결의 절차가 법률에 어긋날 때에 해당하므로 항소심으로서서는 제1심판결 전부를 취소하고 소장의 진술을 비롯한 모든 변론절차를 새로 진행한 다음 본안에 대하여 다시 판단하여야 한다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2004다11988 판결).

그러나 기일통지가 위법한 기일에 행하여진 소송행위도 이에 대하여 바로 이의를 제기하지 아니하면 이의권을 상실하게 되므로 그 흠이 치유된다(민소 151조, 대법원 1984. 4. 24. 선고 82므14 판결). 특히 판례는 판결선고기일을 추후로 지정하였다가 새로 지정한 판결선고기일에 관하여 적법한 기일통지가 이루어지지 않은 채 판결이 선고된 경우에도 그와 같은 위법은 판결에 아무런 영향이 없다고 한다(대법원 1964. 6. 2. 선고 63다851 판결). 나아가 새로 지정된 판결선고기일의 기일통지서가 피고에게 송달되기 전에 판결이 선고되었더라도, 피고가 적법한 기일 내에 항소를 제기하여 항소심의 심리가 이루어졌다면, 그 위법은 판결에 아무런 영향이 없으므로 이를 상고이유로 삼을 수 없다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2001다14023 판결).

제4절 기일의 변경

1. 총 설

기일의 변경이란 기일을 바꾸는 것, 즉 기일을 개시하기 전에 그 지정을 취소하고 대신 새로운 기일을 지정하는 것을 말한다. 기일의 개시 전에 미리 그 지정을 취소하는 점에서, 일단 기일을 개시한 후 아무런 소송행위(변론기일에서의 변론, 증거조사기일에서의 증거조사 등)를 하지 아니하고 새로 다음 기일을 지정하는 기일의 연기와 구별되며, 또 기일을 개시하여 목적인 소송행위의 일부 또는 전부를 하였으나 완결을 보지 못하여 나머지의 또는 새로운 소송행위를 하기 위하여 다음 기일을 지정하는 속행과도 구별된다. 따라서 기일변경의 경우에는 기일의 연기 또는 기일의 속행의 경우와 달리 조서를 작성하지 아니하며, 기일지정권자의 기일변경명령에 기하여 변경기일을 통지하게 된다. 일단 기일이 진행된 이후에는 어떠한 이유에서든지 기일변경은 불가능하고, 그 때문에 설사 기일 해태의 불이익을 주는 것이 부당해 보더라도 마찬가지이다.

민사소송법은 소송절차의 신속을 꾀하기 위하여 기일변경의 요건을 엄격히 하여 첫 변론준비기일이나 변론기일을 제외하고는 현저한 사유가 소명된 경우에만 기일의 변경을 허가하도록 하고 있다. 이러한 기일변경 제한 규정은 변론기일, 변론준비기일뿐만 아니라, 증인신문·감정·서증조사 등 각종 증거조사기일, 화해기일, 조정기일 등에도 그대로 적용된다.

2. 기일변경의 요건

가. 첫 기일의 변경: 합의

첫 변론기일 또는 변론준비기일을 바꾸는 것은 현저한 사유가 없는 경우라도 당사자들이 합의하면 이를 허가한다(민소 165조 2항). 이는 첫 기일은

당사자의 형편을 고려하지 못한 채 직권으로 지정하게 되는 점을 감안하여 당사자의 의사를 존중하자는 취지에서 둔 규정이므로, 변론준비기일과 변론기일을 통틀어 최초의 기일 한 번만을 의미하는 것으로 보아야 한다.

‘첫 기일’은 최초로 지정된 제1회 기일만을 말하고, 당사자의 신청으로 변경되거나 연기된 기일은 포함하지 않으나, 입법 취지에 비추어 당사자의 신청 없이 재판장등이 직권으로 변경한 기일은 첫 기일에 준한다고 해석할 수 있을 것이다. 또한 위 조항이 직접 적용되지는 않으나 기일 추후지정 사유가 해소되어 새로운 기일을 지정하는 때와 같이 당사자의 일정을 확인할 기회 없이 재판장등이 임의로 지정하는 기일의 경우에는 당사자 간 합의를 뒤에서 살펴보는 기일을 변경할 현저한 사유로 볼 여지가 있다.

한쪽 당사자의 기일변경 신청에 대하여 상대방이 동의하지 않을 경우에는 첫 기일이더라도 그 변경의 허가 여부가 법원의 재량에 속하는데(대법원 1966. 10. 21. 선고 66다1439 판결), 미리 당사자의 일정을 확인할 기회가 없었다는 측면에서 속행기일에 비해서는 기일변경이 필요한 현저한 사유를 인정해줄 여지가 크다.

원고 또는 피고가 여러 명이더라도 소송대리인을 공동으로 선임한 경우에는 해당 소송대리인과 합의함으로써 첫 기일 변경을 위한 요건을 충족할 수 있다. 공동소송인들이 소송대리인을 별도로 선임하거나 선임하지 않는 경우에는 원칙적으로 소송대리인이 공통되지 않은 당사자 모두와 기일변경에 대한 합의를 해야 할 것이다.

실무상 당사자 일방이 법정에 출석하여 변론 준비를 충분히 하지 못하였다는 등의 사유로 최초의 기일에 대한 변경신청을 하는 경우가 종종 있는데, 이러한 경우 사건과 당사자를 호명하면 이미 기일이 개시되므로, 사건과 당사자를 호명하지 아니한 채로 미리 상대방의 출석 여부를 확인한 다음 변경 신청에 대한 동의 여부를 물어 기일을 변경하는 형식을 취하는 것이 바람직하다.

나. 제2차 이후 기일의 변경: 현저한 사유

(1) 제2차 이후 기일변경의 제한

제2차 이후의 변론기일 또는 변론준비기일의 변경은 당사자의 합의 여부에 관계없이 현저한 사유가 있는 때에 한하여 허용되며(민소 165조 2항의 반대해석), 당사자가 기일변경신청을 하는 때에는 기일변경이 필요한 사유를 밝히고 그 사유를 소명하는 자료를 붙여야 한다(민소규 40조). 2차 이후의 기일에 관해서는 당사자의 합의에 의한 변경신청이 있더라도 그 허용 여부가 오로지 법원의 전권에 속한다. 또한 변론준비기일을 거친 사건의 경우에 변론기일을 지정하는 때에는 당사자의 의견을 들어야 하고, 그 심리에 2일 이상 소요되는 때에는 가능한 한 변론종결에 이르기까지 매일 변론을 진행하여야 하므로, 그와 같이 지정된 변론기일은 사실과 증거에 관한 조사가 충분하지 아니하다는 이유로 변경할 수 없도록 하였다(72조).

(2) 현저한 사유의 의미

현저한 사유란 불가항력보다는 넓은 개념으로서, 기일변경을 인정하지 않고 기일을 진행함으로써 기일 해태의 불이익을 입게 하는 것이 가혹하다고 할 만한 사정이면 이에 해당될 것이다. 예컨대 파업 등으로 교통두절 상태에 있는 경우, 자기 또는 가족의 혼례·장례에 참석하기 위한 경우, 당해 기일의 통지를 받기 전에 다른 법원으로부터 통지를 받은 경우, 화해를 위한 교섭을 이유로 양쪽 당사자로부터 기일변경의 신청이 있는 경우 등을 들 수 있다. 당사자나 대리인의 예비군훈련 등 다른 국가기관에 출석해야 할 법적의무가 소명된 경우에도 상대방의 동의 여부와 관계없이 기일변경신청을 받아들임이 옳을 것이다. 당사자의 질병의 경우에는 질병의 종류나 정도 등 구체적 사정에 따라 법원이 개별적으로 판단할 문제이다.

종래 실무에서는 현저한 사유를 엄격히 따지지 않고 당사자 사이에 합의가 있으면 비교적 용이하게 기일변경을 허용하는 경향이 있어 소송지연의 한 원인이 되어 왔다. 이를 막기 위하여 민사소송규칙은 민사소송법 165조

2항에 따른 경우 외에는 특별한 사정이 없으면 기일변경을 허가하여서는 아니 된다고 규정하여 기일변경사유에 제한을 가하고 있다(민소규 41조).

원칙적으로 중복되는 일시에 소송대리인인 변호사가 의뢰받은 다른 사건이 있다는 것만으로는 기일변경을 허가할 현저한 사유가 될 수 없다. 이러한 경우 영상재판 방식으로 출석하거나, 당사자 본인 또는 복대리인이 출석하는 것도 가능하다. 위와 같은 사유에 해당하는 경우에도 특별한 사정 유무를 살펴보지 아니하고 기일변경을 허가하여 오던 과거의 실무 관행은 신속한 재판을 위하여 고쳐져야 한다.

(3) 특별한 사정이 있는 경우의 예외

다만 특별한 사정이 있는 경우에는 기일변경을 허가할 수 있다(민소규 41조). 여기서 ‘특별한 사정’이 있는 경우란, 예컨대 나중에 지정된 사건이 선 거소송과 같이 법정기한이 정하여져 있고, 그 사건의 관계인이 여러 사람인 관계로 기일을 변경하는 것이 실제상 매우 곤란한 경우 등이 그 예가 될 수 있다. 그렇지만 앞에서 본 기일변경 제한 규정의 취지에 비추어 볼 때 이러한 특별한 사정의 존부는 엄격하게 해석하는 것이 옳을 것이다.

3. 기일변경의 절차와 고지

가. 기일변경 신청과 그에 대한 재판

(1) 기일변경 신청

기일변경도 기일지정의 한 형태에 불과하므로 기일지정권자의 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 하게 된다. 당사자 등이 기일변경을 신청하는 경우에는 법원의 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없기 때문에 그 신청이 기일에서 이루어졌든 혹은 기일 외에서 이루어졌든 상관없이 모두 인지를 붙이지 아니한다(인지 10조 단서, 인지액·편철방법예규). 기일변경신청에는 앞서 본 바와 같이 변경을 필요로 하는 사유를 밝히고 그 사유를 소명하는 자료를 붙여야 한다(민소규 40조). 기일변경신청에는 희망하는 기일을 기재하기도 하는

데, 기일지정이 어려운 일시가 있을 수 있는 점을 고려하여 희망 기일을 2개 이상 기재함이 바람직하다.

(2) 기일을 변경하는 경우

직권 또는 신청에 의하여 기일을 변경할 때에는 기일지정권자가 기일변경의 취지와 함께 새롭게 지정된 기일이 표시된 기일변경명령[전산양식 A1611]을 발하여 기록에 철하면 된다.

기일을 변경할 때에는 변론을 연기 또는 속행하거나 변론재개결정을 할 때와 마찬가지로 소송절차의 중단·중지 그 밖에 다른 특별한 사정이 없는 한 다음 기일을 바로 지정하여야 하며(민소규 42조, 43조), 추후지정의 형식으로 다음 기일을 지정하지 않은 채 변경하는 일은 피하여야 한다. 다만 민사소송법 279조 2항에 따라 변론기일을 연 뒤에 사건을 변론준비절차에 부치는 경우에는 다음 변론기일을 지정하기가 곤란하므로 추후로 지정할 수도 있다(민소규 42조 1항 단서). 만약 추후지정의 방식으로 변경명령을 할 경우에는 앞의 기일변경명령[전산양식 A1611] 중 ‘변경한 기일’란의 숫자 표시를 ‘추후지정’으로 정정하여야 하고, 그 고지방법은 앞에서 본 변경기일통지서 또는 출석요구서의 사용이 부적당하므로 위 기일변경명령 등본을 송달하는 방식에 의하여야 한다.

(3) 기일을 변경하지 아니할 경우

기일변경신청을 받아들이지 않을 때에는 당초의 지정기일에 기일을 개시하면 되고 따로 신청기각의 재판을 할 필요는 없다. 다만 당사자로 하여금 기일변경 여부를 신속하게 확인하여 후속조치를 취할 수 있도록 기일변경신청에 대한 불허 사실을 통지함이 바람직한 경우가 있을 수 있다. 재판사무시스템을 통해 허부 결재를 하는 경우(민전예규 79조 1항) 별도의 통지가 없더라도 전자소송 당사자는 전자기록뷰어에서 허부를 확인할 수 있다. 기일의 지정·변경·속행은 재판장의 권한사항이므로 법원이 변론연기신청을 받아들이지 아니하고 일방 당사자가 불출석한 가운데 변론과 증인신문을 실시하여

도 절차진행에 위법은 없다(대법원 1992. 11. 24. 선고 92누282 판결). 또한 2차 이후의 변론기일에 한쪽 당사자가 기일변경신청을 하고 양쪽 당사자가 출석하지 않은 경우 재판장이 기일을 변경하지 아니한 채 지정된 변론기일에서 사건과 당사자를 호명하였다면 불출석의 효과가 발생하고, 변론조서에 연기라는 기재가 있다 하더라도 그 기재는 무의미하다(대법원 1982. 6. 22. 선고 81다791 판결).

나. 기일변경명령과 다음 기일의 고지

기일을 변경하는 때에는 바로 당사자에게 그 사실을 알려야 한다(민소규 42조 2항). 기일변경명령의 고지는 전술한 추후지정 방식에 따른 변경의 경우를 제외하고는(즉 변경된 기일이 특정된 경우에는) 통상 변경기일통지서[전산양식 A1612]를 송달하는 방식에 의한다. 전술한 기일변경명령의 등본을 송달하는 방식도 위법은 아니지만, 변경 취지와 변경기일 통지의 취지를 명시한 양식이 제정되어 있는 이상 이를 사용하는 것이 바람직하다.

고지의 상대방은 당사자이지만, 증인·감정인 등 당사자 이외의 사람에 대하여 출석요구를 한 후에 그 기일이 변경된 때에도, 통지할 시간적 여유가 없는 경우 이외에는 바로 그 취지를 출석요구를 받은 사람에게 통지하여야 하는데(민소규 44조 1항), 위와 같이 변경기일통지서[전산양식 A1612]를 송달하여야 할 것이다. 한편 증인·감정인 등 당사자 이외의 사람에 대하여 출석요구를 한 후에 소의 취하 또는 그 밖의 사정으로 인하여 그 기일을 실시하지 않게 되고 또 다음 기일도 지정하지 않는 경우에도 마찬가지로 그 취지를 통지하여야 하지만(2항), 이 경우에는 원칙적으로 출석할 필요가 없다는 취지의 통지서[전산양식 A1635]를 송달하여야 한다.

다만 당사자·증인·감정인 등에게 기일변경의 취지를 서면으로 송달하거나 통지할 시간적 여유가 없는 경우에는 기록에 나타난 전화번호를 통한 구두통지 등 적당한 방법으로 이를 통지하여야 하고(민소규 3조 1항), 전화번호

등의 기재가 없어 부득이 당해 기일 개시 전까지 통지하지 못한 경우에는 기일 개시 직후 바로 그들의 출석 여부를 확인하여 기일이 변경되었다는 사실을 고지하여 줌으로써 출석한 사람이 시간을 낭비하지 않도록 하여야 한다.

제5절 기일의 실시

1. 기일의 개시

가. 기일 개시의 방법

재판을 시작할 때 “지금부터 민사합의(단독)재판을 시작하겠습니다.”라고 개정선언을 함이 바람직하다. 그리고 개정시간이 엄수되어야 함은 두말할 필요가 없다. 부득이한 사정에 의하여 개정이 늦어지는 경우에는 개정이 늦어진다는 취지와 그 사유를 법원경위로 하여금 방청인들에게 고지하도록 하고, 재판장은 법정에 입정한 뒤에 개정이 늦어진 사유와 개정이 늦어져서 미안하다는 취지를 말하는 것이 좋다.

개개의 사건에 대한 기일은 미리 지정된 일시가 도래함으로써 당연히 시작되는 것이 아니라, 소송지휘권을 가진 재판장 등이 지정된 일시에 지정된 장소(법정에서 시행할 기일이면 그 법정, 법정 외에서 시행할 기일이면 그 장소)에서 사건과 당사자의 이름을 부름으로써 시작된다(민소 169조). 사건과 당사자의 이름을 부름, 즉 호명은 기일을 개시하여 변론을 시작하겠다는 선언 행위이다. ‘사건의 호명’은 지정시간이 도래된 뒤에 그 사건이 다른 사건과 구별될 수 있도록 사건번호와 사건명을 분명하게 불러야 하고, ‘당사자의 호명’은 그 당사자의 성과 이름을 부르면 될 것이다. 소송대리인이나 소송수행자의 이름까지 부를 필요는 없고(대법원 1970. 11. 24. 선고 70다1893 판결), 또 당사자가 다수인 경우에는 “○○○ 외 ○명”의 식으로만 하여도 좋다. 한

편 기일에서 당사자를 호명도 하지 아니하였다는 주장은 변론의 방식에 관한 사항으로서, 이는 조서의 기재에 의하여만 증명할 수 있다(대법원 1991. 9. 10. 선고 90누5153 판결).

지정된 시각이 도래하기 전에 사건과 당사자의 이름을 부르는 것은 위법이지만, 소송관계인들의 이의가 없으면 이의권 상실에 의하여 그 흠이 치유된다. 그리고 지정된 시각이 도래된 때에 반드시 호명하여야 하는 것은 아니므로 사정에 의하여 다소 늦어지더라도 위법은 아니고(대법원 1961. 7. 13. 자 4294민재항199 결정), 실무상 앞 사건 진행이 길어지는 등의 사유로 뒤 사건이 지연되는 경우가 빈번하다. 그렇지만 당사자의 대기시간을 최소화하고자 하는 시차제(민소규 39조)의 취지에 따라 과도한 기일지연이 발생하지 않도록 기일지정 과정에서뿐만 아니라 개별 사건별 변론 진행 과정에서도 당초 배분된 시간을 맞추기 위해 노력할 필요가 있다.

지정된 시각이 도래한 뒤에 사건과 당사자의 이름을 부를 때에 당사자가 출석하지 아니하거나 변론을 하지 아니하여야 기일 해태의 효과가 생긴다.

기일 개시의 선언은 변론조서의 재판부 및 법원사무관등 기재 바로 다음에 “사건과 당사자의 이름을 부름”이라고 기재한다.

나. 위법한 기일실시와 이의권의 포기

기일을 실시하기 위해서는 위에서 본 바와 같이 적법한 기일지정과 기일 통지가 있어야 하고 어느 것이라도 빠지면 기일의 실시는 위법이나, 그 기일에 행하여진 소송행위는 당사자의 이의권의 포기 또는 상실에 의하여 유효로 될 수 있다(민소 151조, 대법원 1984. 4. 24. 선고 82므14 판결).

2. 기일의 진행

가. 사건의 진행순서

재판장은 사건의 변론 개정시간을 사건단위로 구분하여 지정하여야 한다

(민소규 39조). 개정시간을 사건단위로 구분하여 지정하므로, 기일에서 사건의 진행순서는 특별히 문제될 게 없다. 다만 앞 사건의 기일이 길게 진행되는 동안에 다음 사건의 개정시간이 도래한 경우에는, 적당한 방법으로 예상 대기시간을 고지하거나 만일 그다음 사건이 당사자 또는 증인의 송달불능·기일변경신청·증거절차미비 등으로 실질적으로 진행될 수 없는 경우라면 증간의 적당한 시간에 그 사건을 먼저 처리할 수도 있을 것이다.

나. 당사자 등 소송관계인의 출석 여부 확인

기일을 실시하기 위해서는 적법하게 기일통지가 되어 있어야 한다. 따라서 사건과 당사자의 이름을 부른 후에 당사자 등 소송관계인의 출석 여부를 확인하되, 먼저 기일통지 여부를 확인하여 기일통지가 적법하게 이루어지지 않은 경우에는 그 내용을 조서에 표시하여야 한다. 그 기일에서 목적인 소송행위의 진행이 가능한지 여부가 가려져야 하기 때문이다.

구체적인 표시방법은 다음과 같다.

(1) 적법한 기일통지가 된 경우

적법하게 기일통지가 이루어진 경우에는 “원고 ○○○ 출석”, “피고 ○○○ 불출석”, “증인 ○○○ 출석”의 식으로 출석 여부만 기재한다. 만일 기일통지서가 공시송달에 의하여 송달된 경우에는 “피고 ○○○(공시송달) 불출석”의 식으로 괄호 안에 공시송달의 기재를 하여야 한다.

[변론(준비기일)조서의 대리인 표시방법에 관한 예시]

- ① 원고 법정대리인 친권자 ○○○ 출석 / ② 원고 지배인 ○○○ 출석
③ 원고 대리인 변호사 ○○○ 출석 / ④ 원고 대표이사 ○○○ 출석

영상재판 방식으로 출석한 경우에는 그 출석유형을 표시한다. 인터넷 화상장치를 이용하여 출석한 경우에는 “원고 대리인 변호사 ○○○(화상장치)”와 같이 성명 뒤에 화상장치를 부기하고, 비디오 등 중계장치에 의한 중계시

설을 통하여 출석한 경우에는 “원고 ○○○(중계시설)”와 같이 중계시설을 부기한다(영상재판예규 25조 1항, 36조).

소송대리인이 있는 경우에 그 소송대리인이 불출석한 때에는 반드시 본인의 재정 여부를 확인한 후 본인이 재정한 때에는 본인을 출석시켜서 변론을 진행하여야 하는데, 이때는 본인의 출석 사실만 기재하면 되지 소송대리인의 불출석 사실을 기재할 필요가 없다. 본인도 불출석한 때에는 본인과 대리인 양쪽 다 불출석하였다는 취지를 “원고 및 대리인 ○○○ 각 불출석”의 식으로 기재하여야 한다(조서예규 3조).

당사자신문을 하기로 예정된 기일에는 그 당사자의 출석 여부를 당사자로서의 지위와 증거방법(신문 대상자)으로서 지위에 관련하여 따로 기재해야 한다. 즉 “원고 ○○○ 출석”, “피고 ○○○ 출석”, “원고 본인 ○○○ 출석”의 식으로 표시한다.

(2) 적법한 기일통지가 되지 않았거나 기일통지 여부를 확인할 수 없는 경우

이 경우에는 해당자의 성명 다음 또는 출석 여부의 표시 바로 앞 등 적절한 위치에 괄호를 하고 그 안에 적법한 기일통지가 없었다거나 기일통지 여부를 확인할 수 없었다는 취지를 간략히 기재하여야 한다. 예컨대 “(미통지) 불출석”, “(송달불능) 불출석”, “(송달착오) 불출석”, “(보정지연으로 미통지) 불출석”, “(송달통지서 미도착) 불출석”, “(공시송달기간 미완료) 불출석” 등의 방식에 의한다.

증인·감정인 등의 출석을 요구한 경우에도 같은 요령으로 그 사유를 괄호 안에 기재하여야 한다. 지난 번 기일에 증인신청을 하여 채택되었으나 증인의 주소, 신문사항 등을 적은 서면(증인신청서)을 제출하지 않았거나 늦게 제출하여 출석요구서를 송달하지 못한 때에는 “(절차불이행으로 미송달) 불출석”, “(절차지연으로 미송달) 불출석”의 식으로 기재하는 것이 통례이다.

적법한 기일통지·출석요구가 없었음에도 불구하고 임의로 출석한 경우에는 다음과 같이 처리한다. ① 당사자의 경우에는 그냥 “출석”으로 기재하면

되며 굳이 “(송달불능, 임의) 출석”의 식으로 기재할 필요는 없다. ② 증인·감정인 등의 경우에는 “(미송달, 임의) 출석”, “(송달불능, 임의) 출석” 등으로 그 증인 등이 적법한 기일통지가 없었음에도 불구하고 임의로 출석하였다는 취지를 기재하는 것이 관례이다. 출석요구서를 받고 출석했던 임의로 출석했던 예납된 여비를 지급해야 한다는 점에서는 차이가 없으나 나중에 소송비용 계산을 할 때 기일통지를 하지 않았음에도 불구하고 송달료가 계산되는 등의 착오 발생을 피하기 위한 주의적 기재라고 이해된다. ③ 재정증인의 경우에는 “재정증인 ○○○ 출석”의 방식으로 재정증인임을 명시하여야 한다.

기일통지서가 공시송달된 당사자가 출석한 경우에는 반드시 영수증[전산양식 A1404]에 송달가능한 주소를 기재하게 하여 당해 기일통지서를 교부한다음, “피고 ○○○ 출석”이라 기재하고 따로 재판장이 “피고 ○○○에 대한 공시송달 명령을 취소”하였다는 취지를 조서의 본문에 기재하여야 한다.

다. 소송행위의 진행

양쪽 당사자에 대한 기일의 통지가 적법하게 된 때에는 재판장의 소송지휘에 의하여 목적인 소송행위의 진행에 들어가게 되는데, 변론기일의 경우에는 변론의 진행이 개시된다(민소 135조 1항). 한쪽 또는 양쪽의 당사자가 여러 명인 경우에 당사자별로 기일통지 여부가 달라진 때에는 기일통지에 흠이 있는 당사자의 변론을 분리하여 적법하게 기일통지가 된 당사자 사이에서만 변론을 진행하는 것이 통례인데, 이때는 “재판장, 피고 ○○○, ○○○에 대한 변론을 분리(분리한다는 결정 고지)”라고 기재하여 당해 기일에서 변론 진행이 되지 않는 부분을 조서에 명시한 다음, 나머지 변론 진행이 가능한 당사자 사이에서 이루어진 변론의 요지를 기재해 나가게 된다. 변론분리결정을 하지 않았더라도 불출석했던 당사자가 속행기일에 출석하여 아무런 이의 없이 변론을 하였다면 이의권 상실에 의하여 종전 기일의 흠이 치유된다.

당사자의 전부 또는 일부에 대하여 변론이 진행된 경우에 변론조서에 변론의 요지를 기재하는 순서는 대략 ① 판결사항의 신청과 이에 대한 답변, ② 공격방법 또는 방어방법에 관한 진술, ③ 석명 관계 등 소송자료의 제출에 관한 사항을 먼저 기재한 다음에, ④ 증거신청과 그 채부 등의 증거결정, ⑤ 증인·감정인 등의 신문 등 증거조사에 관한 사항을 기재하는 것이 통례이다.

①②③에 관한 자세한 내용은 제23장(조서의 작성 및 변론의 녹음) 참조.

④에 관하여는 기록 첫머리에 편철되는 증거목록(서증목록과 증인등목록으로 나뉜다)에 구체적인 사항을 기재하고 기본되는 변론(준비기일)조서에는 “증거관계 별지와 같음”이라고 적은 다음 괄호 안에 해당 증거목록을 표시하여 주는데, 서증목록과 증인등목록 자체가 원고·피고·당사자참가인별로 별도의 용지로 작성되고 있는 점을 감안하여 관계당사자를 함께 표시한다(조서예규 2조). 이에 따르면 “(원고 서증)”, “(피고 증인등)”, “(원고 서증, 피고 서증)”, “(원고 서증·증인등, 피고 증인등)”, “(원고 서증·증인등, 피고 서증·증인등)”과 같이 기재하여야 하며, 예컨대 사실조회신청만 있고 증인신청이 없는 경우에도 “(증인등)”이라고 기재함으로써 증인등목록에 사실조회신청에 관한 사항이 기재된 점이 드러나도록 하여야 한다.

⑤에 관하여는 별도로 마련된 증인신문조서·감정인신문조서·당사자신문조서에 신문내용을 기재하여 기본이 되는 변론조서에 첨부하고 기본조서에는 “별지 조서와 같이 증인, 감정인 각 신문” 또는 “출석한 증인, 감정인 별지 조서와 같이 신문”이라고만 기재한다. 한편 증인신문을 녹음할 경우에는 “민사소송법 제159조 제1항의 규정에 따라 증인의 증언내용을 녹음할 것을 명하고 당사자에게 이를 고지, 별지 조서와 같이 증인신문”이라 기재한다.

④와 ⑤의 순서는 경우에 따라 바뀌는 수도 있다. 예컨대 양쪽 당사자의 서증제출이 있는 후 지난 기일에 채택된 원고 신청 증인을 신문하고 나서 피고가 증인신청을 하여 채택되어 다음 기일에 신문하기로 되었다면, “별지

조서와 같이 증인신문, 증거관계 별지와 같음(원고 서증, 피고 서증·증인등)의 순으로 기재하여도 좋고, “증거관계 별지와 같음(원고 서증, 피고 서증·증인등), 별지 조서와 같이 증인신문”의 순으로 기재하여도 좋다.

증거목록에 기재한 사항이 있을 경우(증거신청, 증거결정, 서증에 대한 인부 등)에는 항상 기본 되는 변론(준비기일)조서에 증거목록 중 해당되는 것을 인용하는 기재를 하여야 하나, 당해 기일에 출석한 증인 또는 감정인의 신문만을 하였을 뿐이라면 “별지 조서와 같이 … 신문”의 기재만을 요할 뿐이며 증거목록에 실시기일의 기재를 했다는 것 때문에 다시 증거목록을 인용하는 기재할 필요는 없다.

제19장

기
일
과
기
간

3. 기일의 종료

가. 기일 종료의 방식

기일은 그 기일에 예정되었던 소송행위가 끝남으로써 종료하는 것이 원칙이다. 따라서 판결선고기일이나 법원 밖의 증거조사기일은 예정된 판결선고나 증거조사가 끝남으로써 자연적으로 종료되며 특별히 종료의 선언을 요하지 않는다. 기일은 또한 다른 사건을 호명하여 그 변론을 시작하는 경우처럼 묵시의 종료선언에 의하여 종료될 수도 있다.

한편 통상의 변론기일은 재판장이 변론의 종결을 선언하거나 연기 또는 속행을 선언한 다음, 다음 기일(판결선고기일 또는 다음 변론기일 등)을 지정 고지함으로써 종료하는 것으로 보아야 한다. 당사자 본인소송의 경우 아라비아 숫자는 혼동되기 쉬워서 다음 기일이 제대로 고지되지 못하는 수가 있으므로, 다음 기일 고지 시 “목요일(재판 요일)” 혹은 “3주일 후”라는 말을 덧붙여 기일을 고지해 주는 것이 좋다. 영상기일에 영상재판 방식으로 출석한 당사자에게 다음 기일을 직접 고지하는 경우 당사자의 의견을 확인하여 다음 기일의 출석 방식을 명확히 하여야 한다(영상재판예규 9조 3항).

나. 기일의 연기 및 속행

연기 및 속행의 의의에 관하여는 변경과의 구별로써 이미 설명하였다(제4절 1. 참조). 기일을 연기 또는 속행할 때에는 소송절차의 중단·중지 기타 특별한 사정이 없는 한 다음 기일을 지정하여야 하며(민소규 42조), 추후지정의 형식으로 다음 기일을 지정하지 않은 채 연기 또는 속행하는 일은 피하여야 한다.

여기서 당사자의 연기신청·변경신청 또는 속행신청이 당해 변론기일에서의 재판장의 소송지휘에 관한 희망의 표시에 불과하다는 점과 이에 따라 인지를 붙일 필요가 없다는 점은 전술한 기일변경 절차에서 설명하였다. 그러한 신청에 의한 연기 또는 속행인지 아니면 법원의 직권 내지 자체적 필요에 의한 연기 또는 속행인지를 조서에 명시하는 것이 실무의 관행이다. 예컨대 신청에 의한 경우에는 “연기(원고대리인의 신청에 의하여)”, “속행(피고대리인의 신청에 의하여)”의 방식으로 기재한다. 직권 내지 자체적 필요에 의한 경우에는 “연기”, “속행” 등으로만 표시할 수도 있으나, 차회 기일에서 용이하게 심리 필요사항을 파악할 수 있도록 조서에 “속행(원고 청구원인 변경을 위하여)” 등으로 속행 사유를 구체적으로 기재하기도 한다.

연기 또는 속행이 당사자별로 달라진 경우(제5절 2. 다.에서 본 바와 같이 일부 당사자에 대한 변론이 분리된 경우를 말한다) 변론조서에 연기와 속행 등 기일의 결과를 표시할 때에는 관계 당사자를 명시하여 “피고 ○○○에 대하여 속행” 또는 “속행(피고 ○○○에 대하여)”라는 식의 표시를 요하며, 특히 변론이 분리된 당사자에 관한 “연기(피고 ○○○에 대하여)” 등의 기재를 누락하지 않도록 주의하여야 한다.

제6절 기일의 해태

1. 총 설

기일은 당사자 기타 소송관계인이 일정한 장소에 모여 소송행위를 함께 하기 위하여 미리 지정된 일시를 말하므로, 이러한 기일에 참석할 당사자 기타 소송관계인이 결석하게 되면 소송진행의 길이 막혀 사건의 해결이 지연될 뿐만 아니라 소송제도의 기능이 마비되게 된다. 따라서 민사소송법은 당사자 또는 소송관계인이 기일에 결석한 경우에 여러 가지 불이익을 줌으로써 소송절차를 원활하게 진행할 수 있도록 하는 제도적 장치들을 마련하고 있다.

먼저, 당사자의 결석에 관하여는 한쪽 당사자가 결석한 경우에는 진술간주(민소 148조)와 자백간주(150조)의 효과가 생기도록 하고, 양쪽 당사자가 결석한 경우에는 소의 취하간주(268조)의 효과가 생기도록 하며, 나아가 불출석한 당사자에게 지연으로 말미암은 소송비용을 부담(100조)시키도록 규정하고 있다. 그 밖에 증인이나 감정인 등 소송관계인이 결석한 경우에는 과태료나 감치(311조, 333조)에 처하도록 규정하고 있다.

이러한 여러 규정들 중에서 소송비용의 부담이나 과태료·감치 처분에 대하여는 각 관련 항목에서 설명하고, 여기서는 당사자의 한쪽 또는 양쪽이 불출석한 경우의 효과에 대하여만 설명하기로 한다.

2. 기일 해태의 요건

가. 필요적 변론기일·변론준비기일

변론기일의 해태란 당사자가 적법한 기일통지를 받고도 ‘필요적 변론기일’에 출석하지 않거나 출석하여도 변론하지 않는 것을 말한다. 따라서 당사자의 주소, 거소 기타 송달할 장소를 알 수 없는 경우가 아님이 명백함에도

재판장이 당사자에 대한 기일통지서를 공시송달에 의할 것으로 명함으로써 당사자에 대한 기일통지서가 공시송달된 경우, 그 당사자는 각 변론기일에 적법한 절차에 의한 송달을 받았다고 볼 수 없으므로, 위 공시송달의 효력이 있더라도 각 변론기일에 그 당사자가 출석하지 아니하였다고 하여 쌍방 불출석의 효과가 발생한다고 볼 수 없다(대법원 1997. 7. 11. 선고 96므1380 판결). 마찬가지로 발송송달이 그 요건을 충족하지 못하여 부적법한 경우에도 쌍방 불출석의 효과가 발생하지 않는다(대법원 2022. 3. 17. 선고 2020다 216462 판결).

임의적 변론기일에서는 그 적용이 배제된다 함이 통설이며, 판결선고기일(민소 207조 2항), 변론기일을 겸하지 않는 증거조사기일(295조)에도 적용이 배제된다. 그러나 변론기일에서 법원이 증인을 신문하기로 하여 변론을 속행할 기일을 지정·고지하였을 경우에는 그 증인조사를 법정 외에서 한다는 특별한 조치가 없는 한 그 고지된 기일은 변론기일이라 할 것이므로 그 고지된 기일에 출석하지 않거나 출석하고서도 변론하지 않은 경우에는 기일 해태의 불이익이 생길 수 있다(대법원 1966. 1. 31. 선고 65다2296 판결). 기일 해태에 관한 규정은 변론준비절차에도 준용되므로(286조) 변론준비기일에도 기일 해태의 효과가 발생하며, 항소심 변론기일도 마찬가지이다(268조 4항, 대법원 1978. 8. 22. 선고 78다1091 판결).

그러나 변론준비절차는 원칙적으로 변론기일에 앞서 주장과 증거를 정리하기 위하여 진행되는 변론 전 절차에 불과할 뿐이어서 변론준비기일을 변론기일의 일부라고 볼 수 없고 변론준비기일과 그 이후에 진행되는 변론기일이 일체성을 갖는다고 볼 수도 없으므로, 변론준비기일에서 양쪽 당사자 불출석의 효과는 변론기일에 승계되지 않고, 따라서 양쪽 당사자가 변론준비기일에 한 번, 변론기일에 두 번 불출석하였다고 하더라도 변론준비기일에서 불출석의 효과가 변론기일에 승계되지 아니하므로 소를 취하한 것으로 볼 수 없다(대법원 2006. 10. 27. 선고 2004다69581 판결).

한편 배당이의의 소의 원고가 ‘첫 변론기일’에 출석하지 아니한 경우에는 소를 취하한 것으로 간주되는데(민집 158조), 변론준비기일의 제도적 취지, 그 진행방법과 효과, 규정의 형식 등에 비추어 볼 때, 여기서의 ‘첫 변론기일’에 ‘첫 변론준비기일’은 포함되지 않는다(대법원 2006. 11. 10. 선고 2005다 41856 판결). 다만 당사자의 참석 및 신속한 진행을 담보하고자 하는 위 조항의 입법 취지에 비추어 배당이의소송은 가급적 변론준비기일 없이 바로 변론기일을 지정함이 바람직할 것이다.

나. 출석하지 아니하거나 변론하지 아니함

(1) 출석하지 아니함

변론기일에 일단 출석하였다가 변론함이 없이 임의로 퇴정하는 것은 물론 소란행위 등에 의하여 퇴정명령을 받아 퇴정 당한 경우(법조 58조 2항)도 이에 해당될 것이다. 변론을 일부 한 다음에 퇴정하는 경우에 관하여는 견해가 대립되어 있는데, 이에 해당되지 않는다고 해석함이 명문의 규정에 비추어 옳다고 본다.

여기에서 당사자란 당사자 본인(소송무능력자인 때에는 그 법정대리인)과 그 소송대리인(복대리인까지 포함)을 포함하는 것이므로, 양자가 모두 불출석하거나 변론하지 아니한 경우라야만 기일을 해태하였다고 할 수 있다. 또한 보조참가인이나 필수적 공동소송관계에 있는 자들 중의 1인이 출석하여 변론하였을 때에는 피참가인 또는 다른 공동소송인이 출석하지 아니하여도 기일 해태의 효과는 발생하지 아니한다(민소 67조 1항, 76조 1항). 또한 재판장이 변론능력 없는 당사자 또는 대리인에게 진술을 금지하고 새 기일을 지정한 경우에(144조 1항), 당사자가 지정된 새 기일에 소송대리인을 선임함이 없이 그대로 출석하면 재판장은 그의 소송관여를 배제할 수 있다. 그렇게 되면 결국 불출석으로 처리되어 기일 해태의 불이익을 입게 될 수 있는 점에 비추어, 법원은 청구의 종류와 내용, 본안소송의 진행경과, 소장 및 답변서 등을

통해 제출한 공격방어방법의 주요 내용, 증명책임 부담에 따른 증거신청 내역 및 변론기일에서의 진술내용 등을 종합하여, 재판장은 당사자에게 필요한 진술을 할 능력이 없어 진술금지 또는 변호사선임명령을 할 필요가 있는지 여부를 신중하게 판단하여야 한다(대법원 2023. 12. 14. 자 2023마6934 결정 참조).

앞서 본 바와 같이, 기일은 지정된 시각이 도래한 후 사건과 당사자의 이름을 부름으로써 개시되는 것이므로 변론기일을 시차제로 하여 사건마다 개정시간을 구분하여 지정한 경우에는 그 지정된 시각이 도래하여 사건과 당사자의 이름을 불렀을 때 출석하지 않으면 불출석의 효과가 발생된다. 다만 여러 사건의 기일이 같은 시간대로 지정된 경우에는 특히 당해 사건이 지정된 시간대가 끝날 때까지(예를 들어 오후 사건을 2시·2시 20분·2시 40분으로 나누어 여러 건씩 기일지정할 경우 2시에 지정된 사건은 2시 20분 직전까지, 2시 20분에 지정된 사건은 2시 40분 직전까지) 기다렸다가 불출석으로 처리함이 바람직할 것이다. 만일 지정된 사건이 그 시간대에 심리가 완료되지 못한 경우에는 그 시간대에 지정된 사건이 모두 심리된 이후를 기점으로 불출석으로 처리한다. 특히 지정된 시각에 변론이 제대로 열리지 못한 상황에서 당사자가 직접 소송을 수행하는 경우, 당사자가 잠시 자리를 비우는 사이 불출석으로 인한 불이익을 입지 않도록 다시 한 번 출석 여부를 확인해 보는 배려를 취하여야 할 것이다.

사건과 당사자의 이름을 불러 불출석을 확인한 후 다음 사건을 진행하고 있는 도중 불출석 당사자가 법정에 들어와 사건 진행을 요청하는 경우가 있다. 이미 해당 사건의 기일이 종료된 이상 원칙적으로 소급하여 변론을 계속할 수는 없다. 다만 불출석처리한 양 당사자가 함께 법정에 들어오거나, 출석한 일방 당사자가 법정에서 나가기 전에 불출석처리했던 다른 당사자가 들어오는 경우에는 양 당사자의 동의를 얻어 당일의 기일을 다시 진행하는 방안을 고려할 수 있을 것이다.

변론기일에 출석하지 아니한 때란 당사자가 적법한 절차에 의한 송달을 받고도 변론기일에 출석하지 않는 것을 가리키므로, 변론기일의 송달절차가 적법하지 아니한 이상 비록 그 변론기일에 당사자가 출석하지 아니하였다고 하더라도 소 또는 상소를 취하한 것으로 보는 효과는 발생하지 않는다(대법원 2022. 3. 17. 선고 2020다216462 판결).

속행기일에 당사자가 기일변경신청을 하고 출석하지 않은 경우 재판장이 기일을 변경하지 아니한 채 지정된 변론기일에서 사건과 당사자의 이름을 불렀다면 불출석의 효과가 발생한다(대법원 1982. 6. 22. 선고 81다791 판결).

(2) 영상재판의 경우

영상재판의 유형에는 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하는 방식과 인터넷 화상장치를 이용하는 방식이 있다(민소 287조의2).

비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하는 경우 당사자, 그 밖의 소송관계인을 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설에 출석하게 한다(민소규 73조의3 1항). 재판장등은 당사자나 증인등의 희망 등을 고려하여 이들이 방문하기 용이한 곳으로 출석법원을 정한 후 출석법원 영상재판담당자의 의견을 들어 호실 등 구체적인 출석장소를 지정한다(영상재판예규 27조 1항). 이 경우 법정과 다른 위치가 출석장소로 지정되었을 뿐 해당 장소에 물리적으로 출석해야 하는 의무를 부담한다는 점에서는 차이가 없으므로, 당사자 등이 재판장의 호명 시점까지 지정된 출석장소에 출석하였는지 여부를 기준으로 불출석 여부를 판단하여야 한다. 따라서 당사자 등이 출석장소에 출석해있었다면 비디오 등 중계시설의 작동 오류 등으로 기일을 진행할 수 없었더라도 출석으로 처리하여야 한다.

반면 인터넷 화상장치를 이용하는 경우 당사자, 그 밖의 소송관계인을 물리적 출석장소 대신 인터넷 화상장치를 이용하여 지정된 인터넷주소에 접속하게 하는 방식으로 출석하게 한다(민소규 73조의3 1항). 따라서 그와 같이 지정된 인터넷주소에 접속하지 아니한 때에는 불출석한 것으로 본다. 다만

당사자등이 책임질 수 없는 사유로 접속할 수 없었던 때에는 그러하지 아니하므로(73조의3 5항), 지정된 인터넷주소에 접속하지 못한 사유에 따라 기일해태 여부가 달라질 수 있다.

법정에 출석해야 하는 기일에서 교통사고 등 현실적으로 출석이 어려운 사유라도 그것이 당사자 측 영역에서 발생한 것이라면 불출석 책임을 부담시킬 수밖에 없다. 마찬가지로 영상재판 방식의 기일에서도 객관적으로 영상재판에 접속할 수 없는 사유, 예를 들어 기간통신사업자가 제공하는 인터넷망 자체의 장애 등은 불출석에 당사자가 책임질 수 없는 사유로 볼 수 있으나, 이와 달리 당사자 측 영역에서 발생한 사유인 경우에는 불출석으로 처리함이 타당할 것이다. 따라서 위와 같은 객관적인 장애 사유를 인정할 수 없다면 특별한 사정이 없는 이상 불출석으로 처리해야 할 것이다. 대리인에게 책임이 있는 경우도 당사자 측 사유로 보아야 한다.

인터넷 화상장치를 이용한 기일에서 불출석(민소규 73조의3 5항)과 통신불량 상태(6항)의 구분이 명확하지 않을 수 있으나, 지정된 인터넷주소에 아예 접속하지 않아야 불출석에 해당하므로 영상재판 프로그램에 접속한 것으로 표시되나 음성 또는 영상의 송수신이 제대로 이루어지지 않는 경우는 원칙적으로 출석은 하였으나 통신이 불량한 상태로 볼 수 있을 것이다.

인터넷 화상장치를 이용한 기일에서 출석이 어려운 객관적인 장애 사유가 인정되어 기일해태의 불이익이 있는 불출석에 해당하지 않는 경우(민소규 73조의3 5항 단서), 조서에는 당사자 등이 불출석하였으나 기일통지서가 적법하게 송달되지 않아 기일해태의 효과가 발생하지 않는 경우에 준하여 “(인터넷 망 장애) 불출석” 등으로 기재할 수 있을 것이다.

(3) 출석하였어도 변론하지 아니함

당사자나 대리인이 출석하였다고 하더라도 변론을 하지 않을 때에는 기일해태가 된다. 영상재판 방식의 기일도 마찬가지이다.

당사자가 변론기일에 출석하더라도 변론하지 아니한 때라는 것은 기일이

개시되어 변론에 들어갔으나 변론을 하지 아니한 경우를 말하는 것이지, 변론에 들어가기도 전에 재판장이 기일을 연기하고 출석한 당사자에게 변론의 기회를 주지 아니함으로써 변론을 하지 아니한 경우에는 출석한 당사자가 변론을 하지 아니한 때에 해당하지 않는다(대법원 1993. 10. 26. 선고 93다19542 판결). 또한 당사자가 출석하였는데 법원이 채택된 증인에 대한 증거절차이행을 촉구하고 증인 출석요구를 위하여 연기한 경우나(대법원 1979. 9. 25. 선고 78다153 판결), 재판장이 출석한 당사자의 동의를 얻어 기일을 연기한 경우(대법원 1990. 2. 3. 선고 89다카19191 판결)에도 출석한 당사자가 변론하지 않은 때에 해당하지 않는다.

반면 출석한 당사자가 연기 또는 기일변경 신청을 하였으나 법원에서 이를 받아들이지 않고 변론을 명하였는데도 변론하지 않았다면 이는 기일의 해태에 해당한다. 여기서 변론에는 본안의 변론이든 본안전의 변론이든 모두 포함된다.

다. 불출석 또는 무변론의 증명

변론방식에 관한 규정이 지켜졌다는 것은 조서로만 증명할 수 있다(민소 158조). 당사자가 변론기일에 출석하지 아니하였거나 출석하여도 변론하지 아니하였는지 여부는 오로지 변론조서의 기재에 의해서만 증명할 수 있다(대법원 1979. 9. 25. 선고 78다153 판결). 따라서 변론조서에 당사자가 출석하였으나 변론한 흔적이 없으면 기일을 해태한 것으로 된다(대법원 1978. 8. 22. 선고 78다1091 판결).

변론조서에 “양쪽 대리인 각 불출석”이라고만 기재되어 있고 당사자 본인의 출석 여부가 기재되어 있지 않은 경우에는 당사자가 변론기일에 출석하지 아니한 사실이 조서의 기재에 의해 증명되었다고 할 수 없다(대법원 1979. 9. 25. 선고 78다153 판결, 대법원 1982. 6. 8. 선고 81다817 판결). 그러므로 이러한 경우에는 반드시 “원고 및 대리인 ○○○ 각 불출석”의 방식으로

본인과 대리인이 모두 불출석하였음을 분명히 기재하여야 한다(조서예규 3조).

위와 같이 출석 여부는 조서의 기재로만 증명할 수 있으므로, 조서의 오류로 당사자가 부당한 피해를 입지 않도록 정확하게 조서를 작성하는 것이 중요하다. 법정녹음 등을 통해 사후적으로 출석 여부에 관한 조서 기재의 오류가 확인되는 경우에도 신속하게 조서정정 절차를 이행하여야 할 것이다[조서정정 절차에 관하여는 제23장(조서의 작성 및 변론의 녹음 등) 제4절 3. 참조].

3. 한쪽 당사자의 기일 해태

가. 총 설

한쪽 당사자가 변론기일(최초의 기일이든 그 후의 기일이든 불문하고 제1심 기일은 물론 항소심 기일과 변론준비기일도 포함한다)에 출석하지 아니하거나 출석하여도 본안에 관하여 변론을 하지 아니한 때에는, 그가 제출한 소장·답변서 그 밖의 준비서면에 적혀 있는 사항을 진술한 것으로 보고 출석한 상대방에게 변론을 명할 수 있다(민소 148조 1항). 이와 같은 처리를 하기 위해서는 진술간주할 소장·답변서 기타 준비서면이 제출되어 있고, 나아가 그 서면이 출석한 상대방 당사자에게 송달되어 있어야 함은 물론이다. 여기서 본안에 관한 변론이란 청구관계사항의 변론임이 원칙이지만, 피고의 소송비용담보의 신청이나 소송요건의 구비에 관한 진술도 포함하는 것으로 본다.

나. 소장·답변서·준비서면 등의 진술간주

법원은 기일을 해태한 당사자가 미리 제출한 소장·답변서 그 밖의 준비서면에 적혀 있는 사항을 진술한 것으로 간주하고, 출석한 상대방에게 변론을 명하고 심리를 진행할 수 있다(민소 148조 1항). 진술간주에 그칠 뿐, 관할 없는 법원에 제소된 경우 본안에 관한 사실만을 기재한 피고의 답변서가 진술간주되었다 하더라도 변론관할의 효과는 생기지 않는다(대법원 1980. 9.

26. 자 80마403 결정).

소장의 제출에 의하지 않고 소가 제기된 것으로 간주되는 경우에는 어느 서면에 기재한 사항을 진술한 것으로 간주할 것인가 문제 된다. 지급명령에 대하여 적법한 이의신청이 있는 경우(민소 472조 2항)에는 이의신청서는 준비서면에 준한다고 볼 수 있으므로 그 기재사항을 진술한 것으로 간주할 수 있다. 그러나 지급명령을 신청한 채권자가 소제기 신청을 한 경우(466조 1항), 그 소제기신청서는 피고에게 송달하지 아니하므로 진술간주될 수 없다. 그 밖에 가압류·가처분신청에 관하여 변론을 여는 경우에는 그 가압류·가처분신청서나 그 결정에 대한 이의신청서는 모두 진술간주의 대상이 된다.

소장·준비서면 등을 진술간주한 경우 변론조서에는 “소장 진술간주”, “피고가 제출한 2000. 5. 10. 자 준비서면 진술간주”, “원고가 제출한 2000. 4. 9. 자 준비서면 진술간주”의 방식으로 한 줄에 이어서 기재한다. 실무의 조서 작성에 있어서 “피고, 준비서면(2000. 5. 10. 자) 진술간주”, “원고, 소장 진술간주” 등으로 불출석한 당사자를 진술간주 행위의 주어로서 기재하고 진술간주 사실을 표시하는 예가 있으나 이는 부적절하다.

진술이 간주되는 서면은 소장·답변서 기타 준비서면 자체에 한하므로, 예컨대 불출석 당사자가 준비서면에 서증의 사본을 첨부하였고 그 준비서면이 진술간주되었다 하더라도 그 사본에 의하여 서증의 제출이 있는 것으로 간주되지는 않는다(대법원 1970. 8. 18. 선고 70다1240 판결, 대법원 1991. 11. 8. 선고 91다15775 판결). 변론에 관한 구술주의의 원칙 때문이다. 만약 서증의 원본을 함께 첨부한 경우에는 기일전의 증거신청(민소 289조 2항)과 관련하여 그 서증제출의 효력을 인정할 것인지 여부가 문제 되는데, 현재의 실무에서는 서증의 신청(제출)은 당사자가 기일에 현실적으로 하여야 하는 것으로 해석하여 역시 서증제출의 효력을 인정하지 않고 있다.

민사소송법 148조 1항에 의하면, 변론기일에 한쪽 당사자가 불출석한 경우에 변론을 진행하느냐 기일을 연기하느냐는 법원의 재량에 속한다고 할

것이나, 출석한 당사자만으로 변론을 진행할 때에는 반드시 불출석한 당사자가 그때까지 제출한 소장·답변서, 그 밖의 준비서면에 적혀 있는 사항을 진술한 것으로 보아야 한다(대법원 2008. 5. 8. 선고 2008다2890 판결).

불출석 당사자 제출의 준비서면 등을 진술간주하고 출석한 상대방에게 변론을 명한 경우에 출석한 상대방이 변론을 하지 않았다 하더라도, 다음에서 설명할 양쪽 당사자의 기일 해태에는 해당하지 않는다고 해석된다. 따라서 특히 원고가 불출석한 경우에 이 진술간주 제도를 적용함에 있어서는 반드시 출석한 피고에게 변론을 할 의사가 있는지 여부를 확인하여 보아 피고가 변론을 하겠다고 하는 경우에 한하여 진술간주의 처리를 하여 진행할 것이고, 피고가 변론을 하지 않겠다고 하는 경우에는 진술간주의 처리를 함이 없이 바로 후술하는 양쪽 당사자의 기일 해태로 처리함이 바람직하다.

다. 진술간주 후의 변론 진행

변론기일에 결석한 당사자가 그때까지 제출한 소장·답변서 그 밖의 준비서면에 기재한 사항은 진술한 것으로 간주되고, 법원은 출석한 상대방 당사자에게 변론을 명하고 심리를 진행하게 된다.

출석한 원고의 청구원인사실 및 기타의 주장사실에 대한 불출석 피고의 인부는 그가 제출하여 진술간주된 답변서 기타의 준비서면의 기재에 의하여 가려지고, 또 출석한 피고의 주장사실 또는 항변사실에 대한 불출석 원고의 인부는 그가 제출하여 진술간주된 준비서면의 기재에 의하여 정해진다. 한편 출석한 당사자는 상대방의 출석 없이도 변론과 증거신청을 할 수 있으나, 이 경우 할 수 있는 변론과 증거조사의 범위는 그가 미리 준비서면에 적은 사실의 주장과 증거신청 및 증거조사에 한정되는 것이 원칙이다(민소 276조).

나아가 변론이나 증거조사가 그 기일에 완결되지 아니할 경우 또는 출석한 당사자가 준비서면에 기재하지 아니한 새로운 사실이나 증거를 제출하려고 하는 경우에는 재판장은 속행될 다음 기일을 지정한다. 만일 변론이나 증

거조사가 완결되었거나 아래에서 보는 자백간주의 결과 소송이 판결을 하기에 충분하도록 성숙하게 되면 변론을 종결하여 선고기일을 고지한다.

라. 자백간주

소장·답변서 그 밖의 준비서면에 기재한 사실에 관하여 불출석한 당사자가 답변서 또는 준비서면조차 제출하지 아니하였거나 제출하였더라도 그 기재에 의하여 이를 명백히 다투고 있지 않은 경우에는, 마치 출석하여 상대방의 주장을 명백히 다투지 않은 경우처럼 이를 자백한 것으로 간주된다(민소 150조 1항, 3항). 이를 자백간주라고 부른다. 다만 그 불출석 당사자가 공시송달에 의한 기일통지를 받은 경우에는 위 자백간주는 적용되지 않는다(3항 단서).

만일 불출석한 피고가 원고의 주장사실을 모두 인정하는 취지의 답변서 기타의 준비서면을 제출하여 진술간주된 경우, 원고의 주장사실에 대한 자백간주로 보아야 하는지, 재판상 자백(민소 288조)이 성립되는 것인지 의문이 있으나, 재판상 자백이 성립한다고 봄이 옳을 것이다. 다만 단순히 상대방의 주장에 단순히 침묵하거나 불분명한 진술을 하는 것만으로는 자백이 있다고 인정하기에 충분하지 않다(대법원 2022. 4. 14. 선고 2021다280781 판결). 진술간주에 의하여 성립된 자백을 취소하려면 그것이 진실에 어긋나고 착오로 말미암은 것임을 증명하여야 한다(288조 단서).

자백간주는 피고 불출석의 경우뿐 아니라 원고 불출석의 경우에도 적용된다. 예컨대 피고가 원고의 대여금청구에 관한 사실을 모두 인정한 후 반대채권으로써 상계한다는 항변을 기재한 준비서면을 제출하였고 이것이 원고에게 송달되었는데, 원고가 이에 대한 아무런 준비서면도 제출하지 않은 채 불출석하였다면 그 상계의 원인 사실에 관하여 원고가 자백한 것으로 간주된다. 그러나 대부분의 경우 피고는 그 기일에 변론(준비서면의 진술 등)을 하지 않는 것이 보통이므로, 원고 불출석으로 인하여 자백간주가 성립하는 경우는 실무상 극히 드물 것이다.

한편 일단 자백간주의 효과가 발생한 후에는 그 이후의 기일통지서가 송달불능으로 되어 공시송달로 진행되었다 하더라도 그 자백간주의 효과는 그대로 유지되므로, 증거로 판단하여 자백간주된 사실과 배치되는 사실인정을 하는 것은 위법하다(대법원 1988. 2. 23. 선고 87다카961 판결). 그러나 일단 제1심에서 자백간주가 있었다고 하더라도 당해 심급에서는 물론 항소심에서 변론 종결 시까지 이를 다투었다면 자백간주가 성립할 수 없다(대법원 1987. 12. 8. 선고 87다368 판결).

마. 포기·인낙·화해의 간주

민사소송법은 당사자가 청구의 포기·인낙의 의사표시를 기재한 답변서 그 밖의 준비서면을 공증사무소의 인증을 받아 제출한 경우에는 그 당사자가 출석하지 않더라도 위 준비서면 등을 진술간주함으로써 그 기재된 취지에 따라 청구의 포기 또는 인낙이 성립된 것으로 보도록 규정하고(민소 148조 2항), 또한 당사자가 화해의 의사표시를 기재한 답변서 그 밖의 준비서면을 공증하여 제출한 경우에도 출석한 상대방 당사자가 그 화해의 의사표시를 받아들인 때에는 그 취지와 같이 화해가 성립된 것으로 보도록 규정하고 있다(3항). 즉 법정에 출석하지 않더라도 서면에 의하여 청구의 인낙·포기 또는 화해를 할 수 있도록 당사자의 편의를 도모함과 동시에, 그 의사의 진정을 확인하는 방법으로서 그 서면에 공증사무소의 인증을 받도록 하여 그 서면의 진정성을 둘러싼 다툼이 없도록 하였다.

다만 화해 서면의 기재가 불명료한 경우에는 무리하게 재판상 화해의 성립을 인정하거나 이를 부정하기보다는, 그 의사를 확인하는 방법으로 화해 권고결정 제도를 이용하는 것이 화해조항의 정확한 정리와 당사자의 진의 파악이라는 측면에서 바람직하다. 이 경우 화해 관련 서면은 그 진술을 보류하는 것이 사후에 그 서면에 의한 화해성립을 둘러싼 다툼을 예방하는 방안이 될 것이다.

4. 양쪽 당사자의 기일 해태

가. 총 설

(1) 세 가지 유형

양쪽 당사자의 해태에는 ① 양쪽 당사자가 모두 불출석한 경우, ② 양쪽 당사자가 모두 출석하였으나 모두 변론하지 않은 경우, ③ 당사자 중 일방은 불출석하고 다른 일방은 출석하였으나 변론하지 않은 경우 등 세 가지 유형이 있다. 어느 경우나 효과는 동일한데, 실무상 원고(또는 항소인)가 결석할 때에는 피고(또는 피항소인)가 변론하지 아니함으로써 양쪽 다 같이 기일 해태가 되는 ③유형이 가장 많다.

(2) 변론조서 작성요령

① 양쪽 당사자가 모두 불출석한 경우에는 출석 여부 표시란에 각각 “불출석”이라 기재하고 본문란에는 아무런 표시를 하지 않는다. 소송대리인이 있는 경우에는 “원고 대리인 ○○○ 불출석”이라고만 표시하여서는 원고 본인의 불출석 여부가 불분명하므로, 반드시 “원고 및 대리인 ○○○ 불출석”이라고 표시하여야 한다(조서예규 3조). 복대리인이 있는 경우에는 그 복대리인의 불출석도 함께 기재하여야 한다. 만일 그 출석 여부에 관하여 아무런 기재가 없다면 조서의 기재로서는 그 기일에 복대리인의 출석 또는 불출석 사실을 증명할 수 없으므로, 기일 해태의 효과가 생기지 않는다(대법원 1967. 12. 18. 선고 67다2202 판결).

② 양쪽 당사자가 모두 출석하고서도 변론하지 않은 경우에는 출석 여부 표시란에 “출석”이라 기재한 후 본문란에 “원고 및 피고, 각 변론하지 아니하다”라고 기재하면 된다. 양쪽 당사자의 소송대리인이 출석한 경우에는 “양쪽 대리인, 각 변론하지 아니하다”라고 기재한다. 이때는 당사자 본인의 출석 여부를 표시할 필요가 없다. 또 “...변론하지 아니하고 퇴정”이라고까지 표시할 필요도 없다.

③ 한쪽 당사자는 불출석하고 다른 한쪽은 변론하지 않은 경우에는 “출

석”과 “불출석”을 각 표시한 후 “피고, 변론하지 아니하다”라는 형식으로 출석 당사자가 변론하지 아니하였다는 취지를 기재하면 된다.

(3) 양쪽 당사자의 불출석과 연기와외의 관계

기일을 개시하였으나 아무 행위를 함이 없이 새 기일로 넘기고 종료하는 것을 연기라고 한다 함은 전술한 바 있으나, 그 기일에 양쪽 당사자가 불출석한 경우에는 연기가 있을 수 없음을 주의하여야 한다. 이 경우에는 당사자 또는 법원의 의사와는 관계없이 양쪽 당사자가 불출석하였다는 사실만으로 민사소송법 268조의 효과(이른바 쌍불의 효과)가 발생되어 버리기 때문에, 더 이상 기일을 연기할 여지가 없는 것이다. 따라서 이러한 때에 변론조서에 연기라고 기재하였다 하더라도 아무 의미가 없고 그로써 양쪽 당사자 불출석의 효과를 저지할 수 없다(대법원 1978. 6. 13. 선고 78다557 판결, 대법원 1982. 6. 22. 선고 81다791 판결). 그러므로 이 경우에는 연기조서를 작성할 것이 아니라 앞의 (2)에서 설명한 바에 따라 양쪽 당사자가 불출석한 경우로 조서를 작성하여야 한다. 다만 아직 공식적으로 사건과 당사자의 이름을 호명하지 않은 상태라면 기일변경을 명함으로써 쌍불 효과가 발생하지 않도록 할 수 있을 것이다.

이 점과 관련하여 특히 주의를 요하는 것은 한쪽 또는 양쪽 당사자가 각 여러 사람이 있는 경우 그중 일부가 불출석한 때의 연기조서의 효력에 관한 것이다. 예컨대 원고 A·B와 피고가 있는 사건에서 원고 A는 출석, 원고 B와 피고는 각 불출석한 경우 또는 원고 A는 송달불능, 원고 B와 피고는 각 불출석한 경우에 있어서, 조서에 “연기”라고 기재되었다면 그 연기의 효과는 출석하거나 송달불능된 원고 A와 피고 사이에서만 발생할 뿐이며(위 78다557 판결), 양쪽 모두 불출석한 원고 B와 피고 사이에서는 연기의 효과가 미치지 않는다. 따라서 원고 B와 피고 사이에서는 “연기”라는 기재에 불구하고 쌍방불출석의 효과가 발생하는 것이므로, 이를 간과하여 만연히 모든 당사자 사이에 기일이 연기된 것으로 처리하거나 이미 취하간주의 효력이 생긴

것을 알지 못하고 계속 심리하는 일이 없도록 주의해야 할 것이다. 그러므로 위와 같은 경우에는 변론조서에 “언기(원고 A에 대하여)”라고 기재함으로써, 연기의 효과가 미치는 당사자가 특정되도록 하여야 한다.

나. 1회의 해태와 새 변론기일의 지정

양쪽 당사자가 모두 변론기일에 출석하지 아니하거나 출석하여도 변론하지 아니한 때에는 재판장은 다시 변론기일을 정하여 양쪽 당사자에게 통지하여야 한다(민소 268조 1항). 양쪽 당사자가 적법한 기일통지를 받고도(167조 1항) 기일을 해태한 경우라야 한다. 기일통지는 앞의 자백간주의 경우와는 달리 적법한 공시송달에 의한 기일통지를 받은 경우도 포함된다(대법원 1977. 1. 11. 선고 76다1656 판결). 이 경우에 변론종결 여부는 법원의 재량이 아니며, 변론의 정도가 판결하기에 충분할 정도로 성숙하였다 하더라도 변론을 종결하는 것은 위법이다.

다. 2회의 해태와 사실상의 휴지 상태

(1) 요건

1회 해태와 마찬가지로 양쪽 당사자가 적법한 기일통지를 받고도(민소 167조 1항) 2회의 기일을 해태한 경우라야 한다(268조 2항). 양쪽 당사자가 2회 모두 불출석하거나 2회 모두 출석은 하였으나 변론하지 않거나 한 번은 변론하지 아니하고 한 번은 불출석하는 경우 등이 모두 포함된다.

이러한 기일 해태는 반드시 연속하여 2회 계속될 필요는 없고 단속적이어도 상관없으나, 적어도 동일 심급의 동종의 기일에서 2회 있어야 한다. 따라서 제1심에서 1회, 항소심에서 1회의 쌍방 기일 해태가 있는 경우에는 2회 기일 해태의 효과가 발생하지 않는다. 같은 심급이라도 환송 전의 항소심에서 1회, 환송 후의 항소심에서 1회의 쌍방 기일 해태가 있는 경우에는 이에 해당되지 않는다고 보는 것이 판례이다(대법원 1963. 6. 20. 선고 63다166 판

결). 또한 동일 심급에서 변론준비기일과 변론기일에 각 1회씩 쌍방 기일 해태가 있는 경우에는 2회의 기일 해태의 효과가 발생하지 않는다(대법원 2006. 10. 27. 선고 2004다69581 판결).

주의할 것은 같은 소가 유지되는 상태에서 2회 내지 3회 불출석하여야 하며, 만일 중간에 소의 교환적 변경이 있고 그 전후에 걸쳐 한 차례씩 불출석한 경우에는 2회 불출석에 해당하지 않는다. 왜냐하면 교환적 변경에 의하여 구 청구는 이미 취하되었기 때문이다. 마찬가지로 본래의 소의 계속 중 양쪽 당사자가 1회 결석한 뒤에 소의 추가적 변경, 반소, 중간확인 소 등 소송중의 소가 제기된 뒤에 다시 1회 불출석한 경우에 2회 불출석의 효과가 미치는 것은 본래의 소에 한하며, 뒤에 제기된 소송중의 소는 1회 불출석으로 보아야 한다. 특히 반소가 제기되어 병합된 상태에서 본소에 관하여는 2회 불출석이 되고 반소는 아직 그에 이르지 못한 경우에는 기일지정과 통지는 반소 사건에 관해서만 하여야 함은 물론이고, 이 경우 기일통지서에도 반소의 사건번호와 반소당사자의 지위만을 표시하여 송달하여야 함을 유의하여야 한다.

(2) 효 과

2회 불출석의 경우에는 1회 불출석과 달리, 판결을 하기에 성숙하였다고 인정될 때에 변론을 종결하여 기록에 의한 판결을 할 수 있는지 견해가 엇갈린다. 그러나 당사자가 2회 불출석하였는데도 판결을 하기에 성숙하였다고 볼 수 있는 경우는 흔하지 않을 것이므로, 법원으로서의 변론종결도 하지 않고 새로운 기일을 지정함도 없이 당해 기일을 종료시켜 사실상 휴지상태에 들어가는 것이 보통일 것이다.

라. 기일지정신청이 없거나 기일지정신청 후의 불출석으로 인한 소취하 간주

(1) 요 건

양쪽 당사자가 2회 불출석한 후 1월내에 기일지정 신청을 하지 아니하거

나 그 기일지정신청에 의하여 정한 변론기일이나 또는 그 뒤의 변론기일에 다시 양쪽 당사자가 불출석하거나 출석하여도 변론하지 아니하면 소를 취하한 것으로 본다(민소 268조 2항, 3항). 즉 2회 불출석 이후 1개월의 휴지기간이 만료되거나 양쪽 당사자가 3회 불출석한 때에 취하간주의 효력이 생긴다. 만일 양쪽 당사자가 2회에 걸쳐 변론기일에 출석하지 아니하였음에도 법원이 직권으로 새 기일을 지정한 때에는 당사자의 기일지정신청에 의한 기일지정이 있는 경우와 마찬가지로 볼 것이다(대법원 2002. 7. 26. 선고 2001다 60491 판결).

이때의 1개월은 양쪽 당사자가 불출석한 변론기일 다음 날부터 기산된다고 할 것이고(민법 157조), 기일지정신청인이 그 사실을 안 때부터 그 기간을 기산할 수 없으며(대법원 1992. 4. 14. 선고 92다3441 판결), 이 기간은 불변기간이 아니므로 기일지정신청의 추후보완은 허용될 수 없다(대법원 1992. 4. 21. 선고 92마175 판결). 사건계속 여부를 조속히 확정하려는 입법 취지에 비추어 법원은 그 기간을 연장할 수도 없다.

민사소송법 268조 2항에 의한 기일지정신청은 소취하 간주의 효력 발생 이전에 이를 저지하는 소송행위로서, 소취하 간주의 효력이 발생한 것으로 보아 일단 종결 처리한 사건에 관하여 그 취하간주의 효력을 다투는 기일지정신청(민소규 67조)과는 그 성질이 전혀 다르다.

민사소송법 268조 2항에 의한 기일지정신청에 대해서는 인지를 붙이지 않고 재판사무시스템에 문건입력한 뒤 본기록에 가철한다(인지액·편철방법예규).

(2) 효 과

양쪽 당사자의 2회 기일 해태 후 기일지정신청이 없거나 그 기일지정신청에 의하여 정해진 변론기일에 양쪽 당사자가 불출석하면 소의 취하가 있는 것으로 본다(민소 268조 2항, 3항). 다만 상소심에서는 소의 취하가 아니라 상소의 취하로 간주되어(4항), 원판결이 그대로 확정된다. 위 규정은 변론준비절차에도 준용된다(286조). 실무상 이를 쌍불취하(雙不取下)라고 한다.

사건종국 시기도 양쪽 당사자가 2회 불출석한 후 1월이 경과한 날 또는 1월 내의 기일지정신청에 의하여 정한 기일이나 그 후의 기일에 양쪽 당사자가 불출석한 때가 되어야 할 것이다(재일 92-8 당사자 쌍방이 2회 불출석한 경우의 사건종국시기).

소취하 간주의 효과는 원고의 의사에 의하여 소가 취하된 경우와 동일하므로 소송계속의 효과는 소급적으로 소멸하며 소송은 종결된다. 소취하 간주는 위 요건의 성취로 법률상 당연히 발생하는 효과로서, 법원이나 당사자의 의사로써 좌우할 수 없다. 설령 당사자에게 소송수행 의사가 있어도 위 효과를 부인할 수 없으며, 법원의 재량이나 사건내용, 소송진행상황을 고려하여 임의로 처리할 수 없다(대법원 1982. 10. 12. 선고 81다94 판결). 또한 소의 취하 간주는 확정적이어서, 당사자에 책임을 돌릴 수 없는 사유로 기일지정신청을 못하였거나 또는 기일지정신청 후의 기일에 결석하였다고 하여 끝난 소송을 부활시킬 수는 없다. 만일 소취하 간주가 되었음에도 이를 간과한 채 본안판결을 한 경우에는 상급법원은 소송종료선언을 하여야 한다(대법원 1968. 11. 5. 선고 68다1773 판결).

(3) 변론조서의 작성 요령

1회의 해태의 경우와 동일한 요령에 의하여 기재하면 된다. 기일지정신청에 의하여 정하여진 기일이나 그 후의 기일에 양쪽 당사자가 불출석한 경우 따로 “취하간주”의 기재를 할 필요가 없고, 종국결과를 확인할 수 있도록 재판사무시스템에 취하간주로 소송이 종료되었음을 입력하면 족하다.

제7절 기일지정신청

1. 총 설

기일지정은 원칙적으로 법원의 직권에 속하므로, 소송절차 진행 중에 당

사자가 하는 기일지정신청은 법원의 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없고, 법원이 이에 대하여 반드시 대답을 할 필요가 없다는 점은 이미 설명하였다. 그러나 이러한 의미가 아닌 것으로 당사자에게 기일지정신청권이 인정되는 경우가 있는데, 여기에는 ① 2회 불출석 후 1개월 내에 하는 기일지정신청(민소 268조 2항), ② 소의 취하가 부존재 또는 무효임을 주장하거나 취하간주의 효력을 다투는 기일지정신청(민소규 67조, 68조)이 있다.

전자의 경우에는 이에 기해 새로 절차를 진행하면 될 것이다. 후자의 경우, 즉 소송이 확정판결에 의하지 아니하고 소나 상소의 취하 또는 취하간주에 의하여 종료된 것으로 처리된 후에 당사자가 그 소송종료의 효력을 다투면서 기일지정신청을 하는 경우(민소규 67조 1항, 68조)에는 재판장 단독으로 신청기각명령 등의 재판을 하는 것이 아니라 법원이 반드시 변론을 열어 소송이 유효하게 종료되었는지 여부를 심리하여야 하므로(67조 2항, 68조) 결국 당사자의 기일지정신청으로 인해 사건계속이 부활하는 법적 효과가 있다고 보아야 하며, 이 점에서 앞서 본 통상의 기일지정신청과 큰 차이가 있다. 다만 새로 지정할 기일에 대한 별다른 시간적 제약은 없으므로 재판장 등은 통상적인 재판일정에 따라 기일을 지정하면 되고, 관련 증거조사 결과의 대기 등 특별한 사정이 있는 경우에는 추후지정하는 것도 가능하다.

소취하(민소규 67조) 또는 취하간주(68조)의 효력을 다투는 경우, 그 취하 또는 취하간주가 부존재하거나 무효임을 주장하는 자가 이를 증명하여야 한다. 취하서가 위조되었다거나 또는 의사에 반하여 제출된 경우가 이에 해당한다.

한편 청구의 포기·인낙 또는 화해의 효력을 다투며 기일지정신청을 하는 경우가 있는데, 판례의 주류적 입장은 청구의 포기·인낙 특히 재판상 화해의 법적 성질에 관하여 소송행위설을 취하고 있어 설사 이들에 흠이 있다 하여도 그것이 재심사유에 해당할 때에 한하여 준재심의 방법에 의해서만 다룰 수 있음을 원칙으로 하고 있으므로, 이와 같은 기일지정신청은 신청자

체로서 부적법하여 각하를 면할 수 없다(대법원 1990. 3. 17. 자 90그3 결정). 설령 그 화해조서의 내용이 강행법규에 위반된다 할지라도 그것은 단지 화해에 흠이 있음에 지나지 아니하여 준재심절차에 의하여 구제받을 수밖에 없다(대법원 2002. 12. 6. 선고 2002다44014 판결).

다만 예외적으로 판결의 당연무효 사유와 같은 중대한 흠이 있는 경우에는 준재심의 소에 의하지 않고도 그 무효를 주장할 수 있다(대법원 1963. 4. 25. 선고 63다135 판결). 따라서 당사자 일방이 화해조서의 당연무효 사유를 주장하며 기일지정신청을 한 때에는 법원으로서서는 그 무효사유의 존재 여부를 가리기 위하여 기일을 지정하여 심리를 한 다음 무효사유가 존재한다고 인정되지 아니한 때에는 판결로써 소송종료선언을 하여야 한다(대법원 2000. 3. 10. 선고 99다67703 판결). 이러한 이치는 재판상 화해와 동일한 효력이 있는 조정조서에 대하여도 마찬가지이며, 비록 당사자 일방이 조정조서에 대하여 불복하면서 제출한 서면의 제목이 ‘이의신청서’라고 하더라도, 그 서면에 기재된 불복사유가 조정 자체가 성립된 바 없는 데도 마치 조정이 성립된 것처럼 조정조서가 작성되어 있어 조정조서가 무효라는 취지라면, 그 서면은 조정조서의 당연무효 사유를 주장하며 한 기일지정신청으로 보아 처리함이 타당하다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다58668 판결).

2. 신청과 접수사무

민사소송규칙 67조, 68조의 규정에 의한 기일지정신청은 서면 또는 말로 할 수 있으나(민소 161조) 실무에서는 대부분 서면으로 하고 있다. 이 신청에는 인지를 붙일 필요가 없다(인지 10조 본문, 인지액·편철방법예규).

위 기일지정신청이 있는 사건에는 따로 사건번호를 붙이지 아니하고 재판 사무시스템 ‘종국입력’란의 종국사유(소취하 등)를 삭제하고 그 이후의 재판 경과 등을 계속하여 전산입력하며, 기록표지 우측상부의 여백에 붉은 글씨로 “기일지정신청사건”이라고 표시하여야 한다(재판사무규 21조 참조). 사건에

관하여 최초로 붙인 사건번호와 사건명은 그 사건이 중국에 이르기까지 이를 사용하여야 하므로(19조 3항 본문) 기일지정신청 사건에는 새로운 사건번호를 붙이지 아니하는 것이다. 그리고 기일지정신청서는 문건으로 전산입력하고 기록에 가철한다(인지액·편철방법예규).

3. 재 판

소 또는 항소의 취하, 취하 간주가 있고 당사자가 그 효력을 다투기 위하여 기일지정신청을 한 경우에는, 법원은 반드시 변론을 열어 신청사유에 관하여 심리하여야 한다(민소규 67조 2항, 68조). 그러나 이에 관한 법원의 심판은 소송이 과연 소취하 등에 의해 유효하게 종료되었는지 여부를 심리·판단하는 것이지 기일지정신청 그 자체에 대해 어떤 판단을 내리는 것은 아니다. 따라서 그 신청이 이유 없으면 결정으로 신청을 각하할 것이 아니라, 판결로써 소송이 종료되었음을 선언하여야 한다(67조 3항). 신청이 이유 있을 때에는 소취하 또는 소취하 간주의 효력을 부정하는 것이 되므로, 취하 당시의 소송 정도에 따라 필요한 절차를 계속하여 진행하고 이에 관하여 중간판결로 그 취지를 선언하거나, 중간판결 없이 중국판결을 한 때에는 그 이유 중에서 반드시 소취하의 부존재 또는 무효의 판단을 표시하여야 한다(67조 3항, 68조).

[판결 주문 기재례]

- ① 이 사건은 2000. 11. 1. 소취하로 종료되었다.
- ② 이 사건 소송은 2000. 11. 15. 소취하 간주로 종료되었다.
- ③ 이 사건에 관한 원고의 2000. 10. 30. 소취하는 무효이다.

4. 중국판결 선고 후의 소취하에 관한 기일지정신청의 처리

중국판결이 선고된 후 상소가 있기 전(즉 상소기간 중) 또는 상소가 있는

후 소송기록이 상소심으로 송부되기 전에 소가 취하된 경우에 그 소취하의 부존재 또는 무효를 주장하는 기일지정신청이 있는 경우의 처리에 관하여는 복잡한 문제가 생길 수 있어 별도의 처리규정이 마련되어 있다(민소규 67조 4항, 5항).

첫째, 상소의 이익이 있는 당사자 모두가 상소를 한 후(원고 승소판결에 대하여 피고가, 원고 패소판결에 대하여 원고가 또는 원고 일부승소판결에 대하여 원·피고 양쪽이 각각 상소를 한 후) 또는 상소의 이익이 있는 당사자 일부만이 상소한 상태에서 나머지 당사자의 상소권이 소멸된 후(원고 일부승소판결에 대하여 원고만 상소하고 피고는 상소기간을 도과한 후)에 소의 취하가 있고 이어서 기일지정신청이 있게 되면, 그에 대한 재판은 원심법원이 하는 것이 아니라 상소법원에서 하여야 한다(민소규 67조 4항 1호). 이 경우는 취하가 무효로 확정되더라도 새로운 상소가 있을 여지가 없기 때문에, 구태여 원심법원에서 재판하게 할 필요가 없고 상소법원에서 재판하게 하는 것이 타당하기 때문이다. 따라서 원심법원의 법원사무관등은 소송기록을 상소법원으로 송부하여야 하고, 상소법원은 그 신청이 이유 없으면 판결로써 소송종료선언을 하여야 하며, 신청이 이유 있는 경우에는 취하 당시의 소송 정도에 따라 필요한 절차를 속행하고 본안판결에 그 판단을 표시하여야 한다.

둘째, 그 밖의 경우, 즉 상소의 이익 있는 당사자 어느 쪽으로부터도 아직 상소가 제기되기 전(상소기간 중)이거나 또는 그중 일부로부터만 상소가 제기되고 나머지 당사자의 상소권 소멸 전(원고 일부승소판결에 대하여 원고만 상소하고 피고는 아직 상소기간 도과 전)에 소의 취하가 있고 이어서 기일지정신청이 있게 되면, 그에 대한 재판은 상소법원이 하는 것이 아니라 원심법원에서 하여야 한다(민소규 67조 4항 2호). 왜냐하면 이 경우는 취하가 무효로 확정되면 그 취하 때문에 상소권을 행사하지 못한 당사자에게 상소할 기회를 주어야 하기 때문이다. 이 경우 원심법원이 신청의 이유가 없다고 인정할 때는 판결로 소송의 종료를 선언하여야 함은 앞서의 일반의 경우(3항 전단)와 같

으나, 신청의 이유가 있다고 인정할 때는 위 일반의 경우(3항 후단)와 달리 판결로 그 소취하가 무효임을 선언하여야 한다. 왜냐하면 이 경우에는 원심에서의 소송절차는 이미 모두 종료되어 있기 때문이다.

원심법원의 소송종료선언 판결이나 소취하무효선언 판결에 대하여는 본안 판결에 대한 상소와는 별도로 상소가 허용됨은 물론이며, 소취하의 무효선언판결이 확정에 이른 때에 비로소 소의 취하가 무효로 확정된다. 이 경우에 판결법원은 종국판결 후에 하였어야 할 절차를 속행하여야 하고, 당사자는 종국판결 후에 할 수 있었던 소송행위를 할 수 있다. 따라서 그 소취하 때문에 상소하지 아니한 당사자에게 상소의 길이 열려야 하는데, 그 상소기간에 관하여는 특별이 정해져 있다(민소규 67조 5항). 이에 의하면 상소기간은 소취하무효선언 판결이 확정된 다음 날부터 전체기간이 다시 기산되도록 하고 있다. 이것은 소취하라는 외부적 사정 때문에 (자신이 책임질 수 없는 사정으로) 상소권을 행사하지 못한 당사자에 대하여, 소취하일까지 이미 경과한 일수를 뺀 기간 동안만의 상소기간을 부여하는 것은 상당하지 아니하기 때문이다(민소 173조 참조).

예를 들어 본다.

2000. 5. 1. 원고일부승소판결 선고(양쪽에 상소권 있음)
5. 8. 원고에게 판결 송달(상소기간은 5. 22.까지임)
5. 9. 피고에게 판결 송달(상소기간은 5. 23.까지임)
5. 10. 원고 항소장 제출
5. 16. 원고 소취하서 제출
5. 26. 원고 취하무효 주장, 기일지정신청
7. 3. 원심법원 소취하무효선언 판결
7. 10. 피고 소취하무효선언 판결에 항소제기
9. 11. 항소기각 판결 선고
11. 7. 상고기각 판결 선고

위의 예시에서 피고는 본안판결(2000. 5. 1. 선고)에 대하여 상소를 할 수 있는데, 그 상소기간은 상고기각 판결 선고 다음 날인 11. 8.부터 전체기간을 새로이 기산한 11. 21.까지이며, 소취하 시까지 이미 경과한 7일(판결송달 다음 날인 5. 10.부터 5. 16.까지)을 공제하지 아니한다.

이상의 설명은 모두 원고·피고가 각각 한 사람뿐인 경우에 관한 것인데, 원고·피고가 각각 여러 명인 경우도 같은 원칙에 의하여 처리하면 될 것으로 본다. 다만 원고가 여러 명인 경우 그중 일부만이 소취하를 한 때에는 그 소취하와 관계없이 나머지 당사자의 상소에 의하여 소송기록 전체가 상소심으로 송부되는데, 그 취하 원고가 소송기록 송부 후에 기일지정신청을 하려면, 위의 기준에 의하여 원심에서 재판해야 할 경우인 때는 원심법원에, 상소심에서 재판해야 할 경우인 때는 상소법원에 각각 신청을 해야 할 것이다.

5. 상소취하서를 원심법원에서 접수처리한 경우의 기일지정신청

종국판결이 있는 후 상소기록을 상소법원으로 송부하기 전에 상소취하서가 원심법원에 접수된 때에는, 원심법원에서 사건을 완결처리하게 되는데, 이 경우 상소취하의 효력을 다투는 기일지정신청을 처리할 법원과 처리절차에 관하여 복잡한 문제가 생길 수 있어 ‘민사상소사건에 관한 상소취하서가 원심법원에 제출된 경우의 업무처리요령’에서 상세한 처리 지침을 정하고 있다.

이에 따르면 이러한 기일지정신청은 상소법원이 처리하여야 하며, 기일지정신청서가 원심법원에 제출된 때에는 소송기록에 기일지정신청서를 첨부하여 상소심으로 송부한다(원심 재판장의 상소장 심사는 생략). 만일 기일지정신청서가 상소법원에 제출된 때에는 원심법원에 기록송부촉탁을 한다. 상소법원에서는 원칙적으로 독립된 사건번호를 부여하여 심리하며, 다른 상소권자에 의하여 이미 사건번호가 부여된 경우에는 별도의 사건번호를 붙이지 않는다. 그 밖에 자세한 내용은 위 재판예규를 참조.

제8절 소송절차의 기간

1. 기간의 종류

가. 행위기간과 유예기간

기간을 정한 목적에 의하여 행위기간과 유예기간으로 구분된다.

행위기간이란 소송사건을 신속·명확하게 처리하기 위하여 특정의 소송행위를 일정한 기간 내에 하여야 하도록 정하여진 기간을 말한다. 행위기간은 다시 당사자의 행위에 관한 기간인 '고유기간'과 법원의 행위에 관한 기간인 '직무기간'으로 나눌 수 있다. 먼저, 당사자 기타 소송관계인의 소송행위에 관한 고유기간은 이 기간을 도과하면 당사자에게 실권 등 불이익이 가해질 수 있는 기간으로서, 소장의 흠 보정기간(민소 254조), 소송능력 등의 흠 보정기간(59조), 담보제공기간(120조 1항), 답변서 제출기간(256조 1항), 주장·증거의 제출기간(147조 1항), 상소기간(396조, 425조), 즉시항고기간(444조), 재심제기기간(456조), 항소이유서 제출기간(402조의2 1항), 상고이유서 제출기간(427조) 등이 있다. 한편 직무기간은 법원의 소송행위에 관한 기간으로서, 혼시적 의미를 지니는 것으로는 판결 선고기간(199조, 207조 1항), 판결 송달기간(210조), 기록 송부기간(400조, 421조, 438조) 등이 있고, 기간 도과 시 일정한 법적 효과가 발생하는 것으로는 심리불속행·상고이유서부제출에 의한 상고기각 판결기간(상고심특례 6조 2항) 등이 있다.

유예기간 또는 중간기간이란 당사자나 그 밖의 소송관계인의 이익을 보호할 목적으로 어느 행위를 할 것인가에 관하여 숙고와 준비를 위하여 일정기간의 유예를 두어야 하는 기간을 말한다. 제척·기피원인의 소명기간(민소 44조 2항), 공시송달의 효력발생기간(196조), 압류일과 매각일 사이의 기간(민집 202조) 등이 그 예이다.

나. 법정기간과 재정기간

법정기간은 기간의 길이가 법에 의하여 미리 정하여져 있는 기간을 말하며, 제척·기피의 원인 및 소명방법 제출기간(민소 44조 2항), 답변서 제출기간(256조), 상소기간(396조) 등이 그 예이다. 한편 재정기간은 각개의 경우에 재판기관이 재판으로 정하는 기간을 말하며, 소송능력 등의 흠 보정기간(59조), 소장의 흠 보정기간(254조), 주장·증거의 제출기간(147조) 등이 그 예이다.

다. 불변기간과 통상기간

앞에서 본 법정기간은 다시 두 가지로 나눌 수 있는데, 그중 법률이 특히 불변기간으로 규정하고 있는 기간이 불변기간이며, 그 밖의 기간이 통상기간이다.

불변기간은 대체로 재판에 대한 불복신청기간으로서 통상기간과 다른 몇 가지 특색이 있는데, ① 법원이 부가기간을 정할 수는 있으나(민소 172조 2항) 이를 늘이거나 줄일 수 없고(1항), ② 당사자 등에게 책임을 돌릴 수 없는 사유로 그 기간이 도과되었을 때 추후보완(173조)이 허용되며, ③ 불변기간의 준수 여부는 직권조사사항에 속하는 소송요건이고, ④ 국민의 재판을 받을 권리와 직접 관계되기 때문에 기간 계산에 오해가 생기지 않도록 명확하게 규정되어야 한다(헌재 1992. 7. 23. 선고 90헌바2 결정).

불변기간의 예로서는 항소·상고 및 즉시항고 기간 등 상소기간(민소 396조 2항, 425조, 444조 2항), 재심제기기간(456조 2항), 제소전화해에 있어서 소제기신청기간(388조 4항), 화해권고결정(226조 2항)·이행권고결정(소액 5조의4)·지급명령(민소 470조 2항)·조정을 갈음하는 결정(민소 34조 5항) 등에 대한 각 이의신청기간, 제권판결에 대한 불복기간(민소 491조 2항), 중재판정 취소의 소의 출소기간(중재법 36조 3항) 등을 들 수 있다.

한편 판례는 상고이유서 제출기간(민소 427조, 대법원 1981. 1. 28. 자 81사 2 결정), 소취하 간주 시의 기일지정신청기간(268조 2항, 대법원 1997. 7. 11.

선고 96므1380 판결)은 불변기간에 속하지 않는다고 한다.

2. 기간의 계산과 진행

가. 기간계산의 원칙

기간의 계산은 민법에 따른다(민소 170조). 이 기간 계산법은 소송법상의 모든 기간에 대하여 적용되며, 그 내용은 대략 다음과 같다.

시, 분, 초로 정한 기간은 즉시로부터 기산하여 소정의 시간이 만료된 때를 종기로 한다(민법 156조).

일, 주, 월 또는 연으로 정한 기간은 초일불산입의 원칙에 따라 초일의 다음 날부터 기산한다(민법 157조 본문). 예컨대 소장의 흠 보정기간은 보정명령 송달일의 다음 날부터, 항소기간은 판결송달일의 다음 날부터 기산한다. 판례는 민사소송법을 준용하는 채무자회생법에 정해진 기간을 계산할 때에도 민사소송법 170조가 기간의 계산을 민법에 따르도록 정하고 있으므로 민법의 기간계산 방식에 따라 초일은 산입하지 않는다고 판시한 바 있다(대법원 2020. 3. 2. 선고 2019다243420 판결).

다만 기간이 당일 오전 영시부터 시작하는 경우에는 초일을 산입한다(민법 157조 단서). 그러므로 판결·결정 등 재판서의 정본이 송달불능되어 공시송달을 한 경우에는 공시송달을 실시한 다음 날부터 기산하여 민사소송법 196조에서 정한 2주일이 지난 다음 날의 영시에 송달의 효력이 발생하므로, 이에 대한 상소기간은 초일을 산입하여 기산한다.

또한 전자소송에서 송달받을 자가 송달 대상 전자문서를 확인하지 않은 때에는 그 전자문서 등재사실의 통지가 이루어진 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 간주하는데(민전 11조 4항), 이에 따라 송달의 효력이 발생하는 시기는 전자문서 등재사실을 통지한 날의 다음 날부터 기산하여 7일이 지난 날의 오전 0시로 산정된다(대법원 2014. 12. 22. 자 2014다229016 명령). 결국 판결문, 화해권고결정, 조정을 갈음하는 결정, 기록접수통지서 등

의 전자문서에 전자송달 간주 규정이 적용되는 경우에는 오전 0시부터 송달의 효력이 발생하여 상소기간, 이의신청기간 또는 항고·상고이유서 제출기간에 초일이 산입되므로, 기간 준수 여부 확인 과정에서 이 점을 주의할 필요가 있다.

기간의 종기는 소정 기간 말일의 종료 시가 된다(민법 159조). 기간을 주, 월, 연으로 정한 때에는 역(曆)에 의하여 계산하여야 하므로(160조 1항) 최후의 주, 월, 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다(2항). 예컨대 1월 20일을 기산일로 하여 6개월이라고 하는 때에는 최후의 월인 7월에서 그 기산일에 해당하는 날인 20일의 전날, 즉 19일이 기간의 말일이 된다.

나. 기간의 시기(始期)

기간의 시기는, 법정기간에서는 법률에 특별한 정함이 없는 한 그 사실이 발생한 때(예컨대 항소기간은 판결이 송달된 때)부터 진행하고, 재정기간에서는 재판으로 시기를 정한 경우에는 그때, 시기를 정하지 아니한 경우에는 그 재판의 효력이 생긴 때부터 진행한다(민소 171조). 예컨대 기간의 시작과 끝을 정하지 아니한 채 ‘5일 이내에’ 담보를 제공하여야 한다고 하는 담보제공명령(117조)이나, 소장의 흠 보정명령(254조 1항)은 당사자에게 상당한 방법으로 이를 고지하면 그 효력이 생기므로(221조 1항), 기간은 결국 위 명령이 고지된 때로부터 진행된다. 따라서 각 소송관계인에게 위 명령이 송달된 시기가 서로 다른 때에는 기간이 진행되는 시기도 서로 달라진다.

다만 후술하는 부가기간은 법원이 정하는 재정기간의 일종이지만, 이는 법정기간인 불변기간과 일체를 이루는 것이므로 이에 관하여는 민사소송법 171조가 적용되지 아니한다. 따라서 부가기간은 불변기간의 만료에 이어 계속하여 진행된다.

한편 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일에 기간이 만료한

다는 민법 161조는 기간의 만료일이 토요일 또는 공휴일에 해당함으로써 발생할 불이익을 막고자 함에 그 뜻이 있는 것이므로 이는 기간의 ‘말일’이 토요일 또는 공휴일인 경우에만 적용되고, 법정기간이나 재정기간을 기산하는 첫날이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 위 규정이 적용되지 않아 바로 그 첫날부터 기산하며, 토요일 또는 공휴일이 기간의 중간에 있는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2004. 4. 28. 자 2004마181 결정 참조).

다. 기간의 종기(終期) — 말일이 공휴일인 경우

기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다(민법 161조). 공휴일은 일요일, 국경일 중 3·1절, 광복절, 개천절 및 한글날뿐만 아니라 ‘관공서의 공휴일에 관한 규정’이 공휴일로 정한 모든 날들, 예컨대 1월 1일·설날 연휴·추석 연휴·석가탄신일·어린이날·현충일·기독탄신일(성탄절) 기타 임시공휴일(대법원 2021. 1. 14. 자 2020모3694 결정)을 포함한다.

라. 기간의 정지

일단 개시된 기간은 소송절차의 중단 또는 중지에 의하여 그 진행이 정지되고, 소송절차의 수계사실을 통지한 때 또는 소송절차를 다시 진행한 때부터 전체 기간이 새로이 진행된다(민소 247조 2항). 이는 기간을 늘인 뒤에도 마찬가지로서, 위 중단 또는 중지사유가 해소된 후에 늘어난 기간을 포함한 전 기간이 새롭게 진행된다.

3. 기간의 신축, 연장과 부가기간

가. 기간의 신축

(1) 기간 신축 요건 및 절차

기간은 당사자 기타 소송관계인이 특정의 소송행위를 하거나 소송행위의

준비를 하기 위한 시간이므로, 그 길이가 부적당하다면 법정기간이나 재정기간이거나를 묻지 아니하고 법원이 이를 늘이거나 줄일 수 있다(민소 172조 1항 본문, 3항).

원칙적으로 기간의 신축은 법원이 직권으로 하는 것이므로, 당사자의 신청권은 인정되지 아니하며, 그 신청이 있더라도 직권의 발동을 촉구하는 의미가 있을 뿐이고, 또한 당사자 간에 기간의 신축에 관한 합의가 있더라도 법원은 이에 구속되지 않으며, 당사자가 이에 불복할 수도 없다.

기간의 신축에 관한 재판은 법정기간인 경우에는 법원이 결정으로 하며, 재정기간인 경우에는 원래의 재판을 담당한 재판기관(법원 또는 재판장, 수명법관)의 구분에 따라 결정 또는 명령으로 한다. 이 재판은 기간의 진행이 시작되기 전에 하는 것이 원칙이고, 기간의 진행이 이미 시작된 이후에는 이를 줄이는 것은 그로 인하여 불이익을 받을 당사자의 동의 없이는 허용되지 않는다.

따라서 원칙적으로 이미 기간이 만료된 다음에 이를 늘이거나 줄이는 것은 허용되지 않는다. 다만 민사집행법 15조에서 정한 항고이유서 제출기간에 관하여, 당사자가 책임질 수 없는 사유로 말미암아 불변기간을 지킬 수 없었던 경우 소송행위의 추후보완을 할 수 있는 것과의 균형상 당사자가 책임질 수 없는 사유로 말미암아 항고이유서 제출기간을 지킬 수 없었던 경우에는 예외적으로 제출기간이 지난 후에라도 민사소송법 172조 1항에 의하여 그 제출기간의 연장이 허용될 수 있다는 판례가 있다(대법원 2024. 6. 27. 자 2024마5813 결정).

(2) 기간을 신축할 수 없는 경우

반면 불변기간은 주로 재판에 대한 불복신청기간으로서 사건처리의 신속·명확을 기하기 위하여 그 길이를 일정하게 할 필요가 있는 것이므로, 그에 대한 신축은 허용되지 아니하고(민소 172조 1항 단서), 다만 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있는 사람을 위하여 부가기간을 정할 수 있을 뿐이다(2

항). 그 밖에도 판결선고기간과 같은 직무기간은 법원 자신이 이에 구속되는 것이므로 늘이거나 줄일 수 없고, 공시송달의 효력발생기간은 이를 늘일 수는 있으나 줄일 수는 없다(196조 3항). 또한 소송행위 추후보완기간이나(173조 2항) 회생채권 또는 회생담보권 신고의 추후보완기간(채무자회생 152조 1항)도 명문으로 그 신축을 불허하고 있다. 나아가 상고이유서 제출기간(민소 427조)은 당사자의 이익을 보장하기 위한 것이므로 그의 동의 없이는 성질상 단축이 허용되지 아니한다.

(3) 기간 신축의 효과

기간을 늘인 경우에는 본래의 기간과 늘어난 기간은 전체로서 합산하여 하나의 기간이 된다. 따라서 기간의 말일이 공휴일인지 여부도 늘어난 기간의 말일이 공휴일인지 여부에 따라서 결정된다. 기간을 줄인 경우에는 그만큼 본래의 기간이 짧아진다.

나. 기간의 연장

항소장에 항소이유를 적지 아니한 항소인은 민사소송법 400조 3항에 따른 항소기록 송부 통지를 받은 날부터 40일 이내에 항소이유서를 항소법원에 제출하여야 하나(민소 402조의2 1항), 항소법원은 항소인의 신청에 따른 결정으로 항소이유서 제출기간을 1회에 한하여 1개월 연장할 수 있다(2항).

항소인이 항소이유서 제출기간 내에 항소이유서를 제출하지 아니한 때에는 항소법원은 결정으로 항소를 각하하여야 하는데, 위와 같이 제출기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 기준으로 각하 여부를 판단하게 된다(민소 402조의3 1항).

다. 불변기간에 대한 부가기간

(1) 앞에서 본 바와 같이, 불변기간에 대하여는 이를 늘이거나 줄일 수 없으나, 주소 또는 거소가 멀리 떨어져 있는 사람에 대하여는 형평의 원칙상

부가기간을 정할 수 있다(민소 172조 2항). 여기의 주소지는 소송대리인이 있으면 대리인의 주소가, 소송대리인이 없으면 당사자의 주소가 그 기준으로 되며, 멀리 떨어져 있는지 여부는 주거와 법원 소재지와의 거리와 교통수단 등 제반 사정을 참작하여 판단할 문제이나, 교통 및 통신수단이 발달된 오늘날에는 별로 의미가 없고, 특히 전자소송 이용자의 경우에는 물리적 거리를 고려할 필요성을 인정하기 어렵다. 당사자 또는 소송대리인의 주거가 멀리 떨어져 있는 이상, 가까운 곳에 송달영수인이 신고되어 있는 경우(184조)에도 부가기간을 정할 수 있다.

그러나 한번 부가기간을 정한 다음에는 다시 부가기간을 정할 수 없고, 또한 일단 불변기간이 경과된 후에는 부가기간을 정할 수 없다. 불변기간을 해태한 경우에 인정되는 추후보완기간(민소 173조 1항)은 불변기간이 아니므로, 이에 대하여는 부가기간을 정할 수 없다(2항).

(2) 부가기간을 정하는 것은 재판에 의한다. 법원의 결정으로 할 수 있지만 판결 주문의 마지막 항에 “피고를 위하여 이 판결에 대한 항소부가기간을 5일로 정한다.” 등으로 기재하는 것이 편리할 것이다. 부가기간의 결정은 법원이 구체적 사정을 고려하여 재량으로 정하는 직권사항이므로, 당사자는 이에 대한 신청권이 없고 신청을 하여도 직권발동을 촉구하는 데 그치므로 그에 관한 법원의 결정에 대하여 불복을 신청할 수도 없다.

(3) 부가기간이 정하여지면 원래의 기간은 그만큼 연장되며, 따라서 원래의 기간과 하나가 되어 결국 연장된 기간을 포함한 전체 기간이 하나의 불변기간이 된다. 따라서 이에 대한 신축은 허용되지 아니하고(민소 172조 1항 단서), 다만 이를 해태한 경우 일정한 요건 하에 추후보완이 인정될 수 있을 뿐이다(173조).

4. 기간의 해태와 소송행위의 추후보완

가. 기간의 준수와 해태의 의미 및 효과

기간은 행위기간에서는 기간 내에 소정의 소송행위를 적법하게 한 때, 유예기간에서는 그 시기로부터 소정의 일, 월 등의 시간이 완전히 경과된 때 각 준수된 것이 된다. 특히 행위기간에 관하여는 후일 그 준수 여부에 관하여 다툼이 생기는 경우도 있으므로, 일단 행위가 된 것은 기록상 명백히 하지 않으면 안 되고 이 점에서 전자문서에 대하여 전산정보처리시스템에 제출시각 정보를 저장하거나, 종이문서에 대하여 법원 접수인을 찍는 것은 중요한 의미가 있다.

기간의 불준수, 즉 해태는 구체적인 경우에 따라 여러 가지 효과를 낳게 되지만, 그중 가장 중요한 것은 불변기간인 재판에 대한 불복신청기간의 해태에 의하여 재판의 확정이라고 하는 결정적인 효과가 생기는 것이다. 통상 기간에서도, 예를 들어 항소이유서 제출기간을 도과한 경우에는 결정으로 항소를 각하하여야 하고(민소 402조의3 1항), 상고이유서 제출기간을 도과한 경우에는 변론 없이 판결로 상고를 기각하여야 하는(429조) 등 재판 종결의 사유가 되는 경우가 있다.

통상 재판에 대한 불복신청기간은 법적 안정성의 요청에 따라 1주 또는 2주로 짧게 설정되어 있다. 그런데 당사자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 불변기간을 준수하지 못한 경우에도 그 재판을 확정시키는 것은 당사자에게 가혹할 뿐만 아니라 형평의 이념에도 반하므로, 이러한 경우에는 특히 소송행위의 추후보완이 인정되고 있다(민소 173조).

나. 기간해태로 인한 소송행위의 추후보완의 요건

(1) 불변기간의 해태

추후보완은 당사자가 그 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 인하여 불변기간을 준수할 수 없었던 경우에 인정된다. 따라서 불변기간이 아닌 다른 통상기

간에는 추후보완이 인정되지 않는다. 판례는 대체로 법률이 불변기간으로 명시하지 아니한 법정기간은 불변기간이 아니라는 취지이다. 예컨대 주소보정기간은 불변기간이 아니고(대법원 1978. 9. 5. 자 78마233 결정), 민사소송법 268조 2항의 기일지정신청기간도 불변기간이 아니며(대법원 1992. 4. 21. 선고 92마175 판결), 민사소송법 456조 3항, 4항의 재심제척기간도 불변기간이 아니어서(대법원 1992. 5. 26. 선고 92다4079 판결), 모두 추후보완이 될 수 없다고 한다. 또한 상고이유서 제출기간 또는 민사집행법이 정한 항고이유서 제출기간에 대해서도 불변기간이 아니므로 추후보완신청의 대상이 될 수 없다(대법원 1981. 1. 28. 자 81사2 결정, 대법원 2009. 4. 10. 자 2009마519 결정). 다만 민사집행법이 정한 항고이유서 제출기간에 관하여, 당사자가 책임질 수 없었던 사유로 말미암아 제출기간을 도과한 경우에는 사후적인 제출기간 연장을 허용함으로써 추후보완신청과 유사한 효과를 거둘 수 있는 예외를 인정한 판례가 있다(대법원 2024. 6. 27. 자 2024마5813 결정).

또한 소송행위의 추후보완은 불변기간 기산의 기초가 되는 송달이 유효한 경우에 비로소 문제 되는 것이므로, 제1심판결을 허위주소에서 다른 사람이 송달받은 경우와 같이 그 송달 자체가 무효인 경우에는 불변기간인 항소기간이 처음부터 진행될 수 없어 항소행위의 추후보완이라는 문제는 생기지 않고, 당사자는 언제라도 항소를 제기할 수 있다(대법원 1994. 12. 22. 선고 94다45449 판결).

(2) 당사자가 책임질 수 없는 사유

‘당사자가 책임질 수 없는 사유’란 천재지변 기타 피할 수 없었던 사변보다는 넓은 개념으로서, 당사자가 당해 소송행위를 하기 위한 일반적 주의를 다하였어도 그 기간을 준수할 수 없는 사유를 말한다(대법원 1991. 3. 15. 자 91마1 결정, 대법원 2004. 3. 12. 선고 2004다2083 판결). 어떠한 사유가 이에 해당하는가의 여부는 결국 법원의 판단에 따라 정해진다.

판례에 의하면, 서울에서 수원으로 배달증명우편으로 발송한 항소장이 4

일 만에 배달된 점(대법원 1991. 12. 13. 선고 91다34509 판결)이나 자신이 구속되었다는 사정(대법원 1992. 4. 14. 선고 92다3441 판결)은 기간을 준수하지 못함에 책임질 수 없는 사유에 해당하지 않는다고 하였다. 여행이나 지방출장, 질병치료를 위한 출타 등으로 인하여 기간을 지키지 못한 경우도 당사자 본인에게 책임질 수 없는 사유에 해당하지 아니한다. 지병으로 인한 집중력 저하와 정신과 치료 등의 사유로 상고기간을 도과한 경우에도, 위 사유는 당사자가 책임질 수 없는 사유에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2011. 12. 27. 선고 2011후2688 판결).

만일 소송대리인이 있는 경우에는 예컨대 소송대리인이 판결정본의 송달을 받고도 당사자에게 그 사실을 알려 주지 아니하여 기간을 지키지 못한 경우처럼 그 책임이 소송대리인에게 있는 이상 본인에게 과실이 없다 하더라도 추후보완 사유에 해당되지 않고(대법원 1984. 6. 14. 선고 84다카744 판결), 그 대리인의 보조인에게 과실이 있는 경우에도 마찬가지이다(대법원 1999. 6. 11. 선고 99다9622 판결). 다만 기간 준수 여부가 문제 되는 사건이 아닌 다른 소송에서 선임된 소송대리인이 그 재판절차에서 기간 준수 여부가 문제 되는 사건의 판결문과 확정증명원을 송달받았다는 사정만으로는 이를 당사자가 직접 송달받은 경우와 동일하게 볼 수 없으므로(대법원 2022. 4. 14. 선고 2021다305796 판결 참조), 이 경우에는 당사자가 직접 해당 사건기록을 열람하거나 새로이 판결 정본을 영수한 시점 등을 기준으로 추후보완 사유 유무를 판단하여야 한다.

판례에 의하여 추후보완이 인정된 사례로는 다음과 같은 사례들이 있다. 당사자와 갈등이 있고 이해관계가 대립되는 가족인 어머니가 판결정본을 송달받은 후 당사자에게 전달하지 아니한 경우(대법원 1992. 6. 9. 선고 92다11473 판결), 당사자의 무권대리인이 소송을 수행하고 판결정본을 송달받은 경우(대법원 1996. 5. 31. 선고 94다55774 판결), 등기우편에 의하여 발송송달된 제1심 판결정본을 수령한 당사자가 그 판결정본 말미에 기재된 문구에

따라 실제 수령한 날부터 14일째 되는 날에 항소장을 제출한 경우(대법원 2007. 10. 26. 선고 2007다37219 판결)에는 모두 당사자가 책임질 수 없는 사유로서 추후보완이 가능하고, 실종자에 대하여 공시송달의 방법으로 소송 서류가 송달된 끝에 실종자를 피고로 하는 판결이 확정된 경우에는 실종자의 상속인으로서의 실종선고 확정 후에 실종자의 소송수계인으로서 위 확정 판결에 대하여 소송행위의 추후보완에 의한 상소를 하는 것이 가능하다(대법원 1992. 7. 14. 선고 92다2455 판결). 또 채권자가 뒤늦게 소송계속 사실을 알고 제1심 변론종결 직후 채무자의 주장을 다투는 서면을 제출하였고, 제1심법원은 법정 외에서 전화를 통하여 채권자에게 변론재개신청서를 제출할 것을 권고하여 채권자가 우편으로 변론재개신청서를 제출하면서 송달이 가능한 채권자의 주소를 아울러 기재하였는데, 그 변론재개신청서가 선고기일 하루 전에 제1심법원에 접수되었으나 법원이 그 접수사실을 알지 못한 채 판결을 선고하고 공시송달의 방법으로 판결정보를 송달한 경우(대법원 2000. 10. 13. 선고 2000다31410 판결)에도 추후보완을 인정하였다. 그 밖에 다음에서 설명하는, 공시송달에서 송달받을 사람이 무과실인 경우에도 추후보완이 가능하다.

(3) 공시송달로 인하여 항소기간을 준수하지 못한 경우

공시송달의 경우에는 그 당사자가 현실적으로 송달서류의 내용을 알 수 있는 경우란 거의 없다. 그러나 제1심 판결정본이 공시송달의 방법에 의하여 피고에게 송달되었다면, 비록 피고의 주소가 허위이거나 그 요건에 미비점이 있더라도 그 송달은 유효한 것이므로, 항소기간의 도과로 그 판결은 형식적으로 확정되어 기판력이 발생한다. 여기서 상소의 추후보완을 인정할 것인지에 관하여, 판례는 공시송달제도의 기능과 송달받을 사람의 이익을 조화롭게 고려하여, 송달받을 사람이 송달사실을 몰랐고 또 모른 데 과실이 없을 것(즉 선의와 무과실)을 요건으로 하여 추후보완이 인정되어야 한다는 견해를 취하고 있다. 이 경우 원고가 공시송달을 신청할 때에 원고에게 과실

이 있었는지 여부는 추후보완의 허부와 관계없는 사항이다(대법원 1987. 9. 22. 선고 87므8 판결).

판례는 일단 통상의 방식에 따라 적법한 송달이 이루어져 당사자가 소송 계속 여부를 알고 있는 경우에는 소송의 진행 상태를 조사하여 그 결과까지도 알아보아야 할 의무가 있으므로, 그 후 공시송달로 진행되어 판결이 송달 되었더라도 항소기간을 지킬 수 없었던 것에 당사자의 책임을 인정한다(대법원 1994. 6. 14. 선고 93다62607 판결, 대법원 1998. 10. 2. 선고 97다50152 판결, 대법원 2001. 7. 27. 선고 2001다30339 판결). 이러한 의무는 당사자가 변론기일에 출석하여 변론을 하였는지, 출석한 변론기일에 다음 변론기일의 고지를 받았는지, 소송대리인을 선임한 바 있는지 여부를 불문하고 부담한다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2004다16082 판결, 대법원 2015. 12. 10. 선고 2015다48276 판결). 또한 법인인 소송당사자가 법인이나 그 대표자의 주소가 변경되었는데도 이를 법원에 신고하지 아니한 경우나(대법원 1987. 2. 24. 선고 86누509 판결) 당사자가 주소변경신고를 하지 않아(대법원 2004. 3. 12. 선고 2004다2083 판결), 결과적으로 공시송달의 방법으로 판결 등이 송달된 경우에도 추후보완을 인정하지 아니한다.

그러나 한편 조정이 성립되지 아니한 것으로 사건이 종결된 후 피신청인의 주소가 변경되었음에도 피신청인이 조정법원에 주소변경신고를 하지 않은 상태에서 민사조정법에 따라 조정이 소송으로 이행되었는데, 통상의 방법으로 변론기일통지서 등 소송서류를 송달할 수 없게 되어 발송송달이나 공시송달의 방법으로 송달한 경우에는 처음부터 소장부분이 적법하게 송달된 경우와 달리 피신청인에게 소송 진행상황을 조사할 의무가 있다고 할 수 없으므로, 피신청인이 소송 진행상황을 조사하지 않아 상소제기의 불변기간을 지키지 못하였다면, 이는 당사자가 책임질 수 없는 사유로 말미암은 것에 해당하여 추후보완을 인정한다(대법원 2015. 8. 13. 선고 2015다213322 판결). 소장부분 등이 이미 공시송달의 방법으로 송달된 상태에서 제1심법원이 피

고에게 전화로 연락하였더라도, 그 통화 과정에서 소장부분 송달에 관한 내용과 변론기일 등을 안내해 주었다는 정도의 사정만으로는 제1심판결이 공시송달의 방법으로 송달된 사실을 피고가 모른 데 대하여 피고에게 책임을 돌릴 수 있는 사유가 있다고 선불리 단정하기 어렵다고 보아 추후보완을 인정한다(대법원 2021. 8. 19. 선고 2021다228745 판결).

또한 당사자가 소송계속 여부를 안 경우라 하더라도 법원의 잘못이 개재되어 공시송달이 이루어지게 된 경우에는 추후보완을 인정한다. 예컨대 법원의 부주의로 주소를 잘못 기재하여 송달한 탓으로 송달불능이 되자 공시송달을 한 경우(대법원 1990. 8. 28. 자 90마606 결정), 당사자가 변론기일에 빠짐없이 출석하였는데 법원이 직권으로 선고기일을 연기하면서 그 통지를 누락하고 판결정본을 한여름 휴가철에 연속 송달하였다가 폐문부재로 송달불능되자 이를 공시송달한 경우(대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다19069 판결)가 이에 해당한다. 나아가 원고의 주소가 정확하고 변동이 없음에도 우편집배원의 경솔하고 불성실한 업무처리로 인하여 주소불명이라는 이유로 송달불능으로 반려하거나(대법원 1982. 12. 28. 선고 82누486 판결), 불성실한 우편집배인이 '이사 간 곳 불명'이라는 이유로 기일통지서를 반려(대법원 1977. 1. 11. 선고 76다1656 판결)한 까닭에 공시송달의 방법으로 진행된 경우에도, 모두 당사자가 그 책임 없는 사유로 인하여 기일에 출석하지 못한 경우에 해당한다.

반면 처음 소장부분 송달부터 공시송달의 방법으로 소송이 진행된 경우라면, 그것이 원고가 허위의 주소를 신고한 때문인 경우는 물론 그렇지 않다 하더라도 특별한 사정이 없는 한 항소제기기간을 준수하지 못한 것은 당사자의 책임질 수 없는 사유로 인한 것이어서 추후보완이 인정된다(대법원 1981. 3. 24. 선고 80다2739 판결, 대법원 1997. 8. 22. 선고 96다30427 판결, 대법원 2000. 9. 5. 선고 2000므87 판결). 이는 당사자가 이사하면서 전출입 신고를 하지 아니하여 주민등록 있는 곳에 실제 거주하지 않고 있더라도 마

찬가지이다(대법원 1968. 7. 23. 선고 68다1024 판결).

(4) 허위주소로 송달한 사위판결의 경우

위와 같이 공시송달에 의하여 소송절차가 진행된 결과 판결이 선고된 경우 이외에도, 실무상 당사자가 법원에 상대방의 주소를 허위로 표시하여 상대방이 모르는 사이에 판결을 얻어내는 경우가 있다. 즉 원고가 피고의 주소를 허위로 표시하여 그곳으로 소장부본과 변론기일통지서를 송달하게 한 다음(피고 아닌 타인이 송달을 수령하도록 함) 마치 피고 자신이 송달받고도 불출석한 것처럼 법원을 속여 자백간주에 의한 승소판결을 얻어내는 경우이다.

판례는 이 경우 그 판결의 송달 자체가 무효이므로 아직 그 판결이 피고에게 송달되지 않은 상태(즉 미확정상태)가 계속되는 것으로 보고 있으며, 따라서 피고는 언제든지 통상의 방법에 의한(즉 추후보완의 방식에 의하지 아니한) 상소를 제기할 수 있고, 상소의 추후보완이라든가 재심청구(민소 451조 1항 11호)는 허용되지 않는다는 입장을 취하고 있다(대법원 1978. 5. 9. 선고 75다 634 전원합의체 판결, 대법원 1994. 12. 22. 선고 94다45449 판결). 반면 상대방의 주소를 허위로 표시한 것이 아니라 대표자 자체를 허위로 표시한 경우에는 민사소송법 451조 1항 3호의 재심사유에 해당하므로(대법원 1999. 2. 26. 선고 98다47290 판결), 허위표시의 대상이 무엇인지 확인할 필요가 있다.

또 판례는 원고가 피고의 주소를 알고 있으면서도 허위의 주소 또는 소재 불명으로 표시하여 법원으로부터 공시송달명령을 얻어내어 판결을 받아 확정시킨 경우에는 그 판결이 일단 확정된 것으로 보고 재심청구(민소 451조 1항 11호)까지 허용하고 있다(대법원 1974. 6. 25. 선고 73다1471 판결). 따라서 이러한 경우에는 앞서 본 상소의 추후보완과 재심청구 중 어느 쪽을 택하여도 무방한데(대법원 1980. 7. 8. 선고 79다1528 판결, 대법원 1985. 8. 20. 선고 85므21 판결), 추완상소와 재심의 소는 독립된 별개의 제도이므로, 추완상소 기간이 도과하였다 하더라도 재심제기기간 내에는 재심의 소를 제기할 수 있다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다73540 판결).

다. 추후보완의 절차 및 재판

(1) 추후보완의 신청

추후보완을 함에는 추후보완을 하는 자(당사자·소송대리인·보조참가인 등)가 해태한 소송행위를 그 방식에 따라서 하면 되고, 따로 추후보완의 신청 같은 것은 필요 없다. 예컨대 항소의 추후보완을 하는 경우라면 항소장을 제출하는 것만으로 충분하다. 다만 실무에서는 ‘추후보완항소장’임을 명기하는 것이 관례이며 또 그렇게 하는 것이 편리하다고 하겠다.

(2) 추후보완의 기간

추후보완을 하여야 할 시기는 불변기간을 지킬 수 없었던 사유가 없어진 후부터 2주 이내이다(민소 173조 1항 본문). 다만 그 사유가 없어질 당시 외국에 있던 당사자에 대하여는 국제우편으로 소송서류를 송달하는 데 소요되는 기간으로 인한 불이익을 구제하기 위하여 추후보완 기간을 30일로 한다(1항 단서). 여기서 ‘외국에 있던 당사자’란 장기해외여행 중인 자, 외국거주·체류 중인 자를 의미한다. 위 추후보완기간은 불변기간이 아니므로 성질상 부가기간을 정할 수 없고, 통상기간에 해당함에도 민사소송법 173조 2항에 따라 법원의 재판에 의해 그 기간을 늘이거나 줄일 수 없다.

여기서 ‘그 사유가 없어진 때’란 천재지변 기타 이에 유사한 사실의 경우에는 그 재난이 없어진 때이고, 판결의 송달사실을 과실 없이 알지 못한 경우에는 당사자나 소송대리인이 단순히 판결이 있었던 사실을 안 때가 아니라 나아가 그 판결이 공시송달의 방법으로 송달된 사실을 안 때를 가리키는 것으로서, 다른 특별한 사정이 없는 한 통상의 경우에는 당사자나 소송대리인이 그 사건기록의 열람을 하거나 또는 새로이 판결정본을 영수한 때에 비로소 그 판결이 공시송달의 방법으로 송달된 사실을 알게 되었다고 보아야 한다(대법원 1994. 10. 21. 선고 94다27922 판결, 대법원 1997. 8. 22. 선고 96다30427 판결, 대법원 2000. 9. 5. 선고 2000므87 판결). 특히 이혼사건의 경우에는 가족관계등록부의 이혼사실 기재를 확인한 것만으로는 장애사유가 중

료되었다고 할 수 없다(대법원 1990. 3. 13. 선고 89므1023 판결). 만약 전화로 판결 선고와 송달 사실을 알게 되었다면, 그때가 장애사유의 종료시기가 된다(대법원 1993. 9. 28. 선고 93다29860 판결).

(3) 추후보완 허부의 재판

추후보완사유는 소송요건으로서 직권조사사항이므로, 법원은 본안심리에 들어가기에 앞서 이에 관한 당사자의 주장이 명료하지 않은 경우 석명권을 행사하여 이를 명확히 하여야 한다(대법원 1999. 2. 9. 선고 98다43533 판결, 대법원 2014. 7. 10. 선고 2014다13181 판결). 추후보완사유에 관한 당사자의 주장은 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없어 이에 대하여 판단하지 아니하였다고 하더라도 판단누락의 상고이유로 삼을 수 없고(대법원 1999. 4. 27. 선고 99다3150 판결), 당사자가 항소를 제기하면서 ‘추후보완항소’라는 취지의 문언을 기재하지 아니하였다 하더라도 그 전체적인 취지에 비추어 그러한 주장이 있는 것으로 볼 수 있는 경우에는 당연히 그 사유에 대하여 심리·판단하여야 하며, 증거에 의하여 그 항소기간의 경과가 그의 책임질 수 없는 사유로 말미암은 것으로 인정되는 이상, 그 항소는 처음부터 소송행위의 추후보완에 의하여 제기된 항소라고 보아야 한다(대법원 1980. 10. 14. 선고 80다1795 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2007다41560 판결).

추후보완 사유의 존재, 즉 송달받은 사람이 자기에게 책임을 돌릴 수 없는 사유로 송달 사실을 몰랐다는 사실에 관하여는 추후보완하는 자가 주장·증명하여야 하며, 추후보완된 소송행위를 심리할 법원이 이를 심리·재판한다. 법원은 추후보완사유에 한하여 변론을 제한할 수 있다(민소 141조). 항소인이 추후보완 사유를 주장하는 경우에 그 사유 주장의 이유 유무에 대한 심사는 민사소송법 399조 2항이 정한 항소장심사권한에 포함되어 있지 아니하므로(대법원 2006. 5. 19. 자 2006마354 결정), 제1심법원의 재판장은 추후보완항소장이 민사소송법 397조 2항에 위배되거나 인지를 붙이지 아니하는 등 항소장 자체의 각하사유가 있는 경우에만 명령으로 항소장을 각하할

수 있고, 그러한 각하사유가 없다면 소송기록을 항소심법원에 송부하여야 할 것이다.

추후보완은 별도의 독립된 신청이 아니므로, 법원은 추후보완의 사유가 있다고 인정되면 독립된 재판을 할 필요 없이 추후보완을 인정하여 본안에 관하여 재판하면 되고, 만일 추후보완 사유가 없는 때에는 추후보완된 소송 행위는 불변기간을 도과한 부적법한 것이므로 이를 각하하는 재판(예컨대 항소각하·상고각하 등)을 한다(대법원 1966. 3. 22. 자 66마71 결정).

(4) 상소의 추후보완과 판결의 집행력

판결은 상소기간이 도과되면 바로 확정되어 집행력이 발생하므로, 추후보완 소송행위를 하는 것만으로는 불복항소의 대상이 된 판결이 취소될 때까지는 확정 판결로서의 효력이 배제되는 것은 아니다(대법원 1978. 9. 12. 선고 76다2400 판결). 따라서 패소한 당사자가 추후보완을 하면서 그에 의한 집행을 저지하려면 민사소송법 500조에 의한 강제집행정지를 신청하여 강제집행의 일시정지나 강제처분의 취소를 받아야 한다.